

directo a nuestro sistema procesal actual, acelerándolo mediante la supresión de una de sus dos etapas tradicionales, pero respetando el principio de celeridad requerido para los alimentos, ya que se reserva para estos últimos el carácter de proceso sumarísimo.

Con esto he intentado evidenciar el sentido humano del derecho romano, puesto que sus principios rectores privilegian el derecho a la vida de la persona, permitiéndole recibir una adecuada alimentación, consistente en comida, bebida, vestimenta, estudios, lugar para habitar y demás gastos inherentes, adecuando el procedimiento a la premura y efectividad de su percepción.

XX. LA LEGISLACIÓN MATRIMONIAL DE AUGUSTO O LEYES CADUCARIAS

Hace referencia a las leyes dictadas durante el gobierno de Augusto sobre la materia. Primero, la lex Iulia de maritandis ordinibus(18 a.C.) y en segundo lugar, a la lex papia poppaea (año 9 d.C.)⁽¹³⁰⁾.

Una de las finalidades de la política de Augusto es alentar el incremento de la población, ya que bajo el Imperio ésta merma demasiado a causa de las guerras civiles⁽¹³¹⁾. Además, intenta detener el relajamiento de las costumbres, debido que en dicha época proliferan las uniones no permanentes, ilegítimas o transitorias. Su intención es restaurar la pureza de las antiguas costumbres. También se advierte otro propósito, aunque subyacente, destinado a buscar el aumento de la recaudación de impuestos.

El sistema común a ambas leyes es el de imponer premios y castigos, según la condición de casados o solteros, y se tengan o no hijos. Estas leyes inducen al célibe a contraer matrimonio. La lex Iulia impone esta obligación al varón comprendido entre la edad de 25 y 60 años; y a la mujer entre los 20 y 50 años. La condición de divorciado o viudo, tanto para el hombre como para la mujer, no es óbice para cumplir con la obligación de contraer nuevas nupcias al poco tiempo de superar el padecimiento, estableciendo plazos al respecto.

La Lex Papia Poppaea exige a los casados procrear hijos legítimos y los premia si lo logran; así, las mujeres ingenuas que tengan tres hijos y las libertas que tengan cuatro quedan eximidas de tener tutela. En cambio, los solteros o casados sin hijos no pueden recibir liberalidades testamentarias, que pasan a los otros parientes con hijos o, en su defecto, al Estado⁽¹³²⁾. Otra de las ventajas que benefician a aquellos que cumplen con el mandato legal es la preferencia en la solicitud y obtención de cargos públicos. Posteriormente, los emperadores Septimio Severo y Antonino Caracalla completan el sistema legal, ordenando castigar con el destierro el aborto deliberado de la mujer. Finalmente, el cristianismo torna en inocuas las disposiciones de las "leyes caducarias", hasta que lentamente caen en desuso, encontrándose en el derecho justinianeo meras alusiones a ellas.

XXI. EL CONCUBINATO⁽¹³³⁾

El concubinato es una institución aceptada de modo alternativo al matrimonio. Empero, lo que es bien visto social y legalmente en Roma es el matrimonio legítimo, contraído con las formalidades exigidas por la ley. Mas, en otros casos, se acepta la simple cohabitación de una pareja que no puede casarse legalmente a causa, por lo general, de una desigualdad social, v.gr., hombre libre y mujer liberta. Esta situación de hecho es contemplada por los juristas, de tal modo que si una pareja no puede contraer justas nupcias, bien puede convivir en concubinato. Es decir que si bien el concubinato no es considerado una unión en justas nupcias, consiste en una unión aceptada legalmente. Su característica primordial es la ausencia de transitoriedad, siendo una unión permanente y duradera⁽¹³⁴⁾. No pueden coexistir ambas instituciones en forma paralela, es decir, no se puede tener esposa y concubina al mismo tiempo, resultando incompatible con un matrimonio no disuelto.

La unión en concubinato no aparea la equiparación de la mujer al rango social del marido, ni tampoco ésta adquiere la dignidad de esposa (honor matrimonial)⁽¹³⁵⁾.

Los hijos habidos de la relación de concubinato no adquieren la legitimidad, sino que se los considera hijos naturales. Toman la condición jurídica de la madre en el momento de la concepción,

considerándoselos en un principio como si no tuvieran padre, adquiriendo el parentesco de cognación con la madre y sus parientes. Pero luego, lentamente, tal dureza se atenúa y se les comienzan a reconocer derechos de importancia, como el de sucesión y el de alimentos⁽¹³⁶⁾. Durante el Bajo Imperio, principalmente desde Constantino, se reconoce definitivamente el parentesco natural entre el padre y los hijos nacidos en concubinato, llamándoselos *liberi naturales*, de tal modo que el padre los puede legitimar si contrae justas nupcias con la concubina⁽¹³⁷⁾. Finalmente, Justiniano recoge esta evolución, brindando a los hijos habidos de una relación de concubinato los derechos sucesorios y alimentarios, exigiendo para el concubinato los mismos requisitos e impedimentos requeridos para contraer matrimonio⁽¹³⁸⁾.

FRANJA
MORADA

I. BREVE INTRODUCCIÓN AL TEMA

Es una preocupación constante del jefe de familia (pater familias) en Roma poner en orden sus cosas, principalmente en lo que concierne al futuro de la familia y el destino de su patrimonio una vez acontecido su deceso. Por tal motivo, no se descuida jamás lo atinente al traspaso, si se quiere, ordenado de la familia para después de su muerte.

Desde muy antiguo se encuentran vestigios del derecho sucesorio romano. En primer lugar, se comienza con el derecho sucesorio testamentario, puesto que los romanos utilizan el testamento como medio eficaz de disposición de última voluntad. El testamento es una invención puramente romana, desarrollada lentamente por los juristas hasta convertirlo en el medio idóneo para plasmar la decisión postrera del "jefe de familia", cualquiera sea su forma, disponiendo así de su patrimonio.

Puedo afirmar que el testamento, en cuanto implica hacer referencia al derecho sucesorio testamentario, nace y evoluciona junto con la ciudad primitiva. Más tarde se presentan en la misma vida cotidiana otras circunstancias que es necesario contemplar, prescindiendo de la última voluntad del causante, v.gr., falta de testamento, nulidad del mismo, un hijo póstumo, herederos forzosos no contemplados, etc. Estas variantes son contempladas y suplidas ante la carencia de la voluntad del "jefe de familia" por la voluntad presunta de la ley. Esto genera el nacimiento de la sucesión llamada legítima o sin testamento (ab intestato). Después, evolución mediante, el sistema sucesorio romano, testamentario o legítimo, es adoptado por todos los pueblos que de algún modo u otro están ligados al mundo romano, incluso el nuestro.

II. CONCEPTO DE SUCESIÓN. CLASES

Sucedere significa sustituir, continuar, reemplazar, a alguien en la titularidad de un derecho. La sucesión puede originarse por "acto entre vivos" (successio inter vivos) o por "causa de muerte" (successio mortis causa). Ambas, a su vez, pueden ser a título universal (per universitatem) o particular (in singulares).

La primera consiste en el traspaso en bloque de todo el patrimonio de una persona a otra, y la segunda sólo se refiere a un bien o derecho en particular. En Roma se produce la sucesión universal entre vivos, v.gr., en el caso de la "adrogación" (adrogatio). Por su parte, la sucesión particular entre vivos la encontramos en la cesión de un derecho, por ejemplo, la compraventa.

La sucesión universal por causa de muerte la tenemos en la transmisión de la herencia según el derecho civil (hereditas) o de acuerdo con el derecho honorario (bonorum possessio). La sucesión particular por causa de muerte se presenta en el caso del legado⁽²⁾.

1. La herencia (hereditas)

Es la sucesión que corresponde a los ciudadanos romanos regulada por el derecho civil (ius civile). Se la define como el conjunto de derechos reales y personales y las obligaciones, cargas y deudas que conforman el patrimonio de una persona y que son transmitidos a su muerte.

La herencia (hereditas) es propia del derecho civil (ius civile), aunque su origen es previo a la ley de las XII Tablas. En principio, se regula por la costumbre y luego es recogida por esta ley.

La herencia romana es un sistema rígido, adaptada por completo al excesivo formalismo de las relaciones jurídicas de la primitiva época, regida por el "derecho quiritarario" (ius civile). En este sistema, una vez fallecido el titular del patrimonio (sui iuris), se llama a recibir la herencia (hereditas) en calidad de sucesor a quien recibe el nombre de heredero (heredes). Este último recibe todos los derechos y obligaciones del fallecido, por cuanto ocupa su lugar como si continuase su persona. Se produce una confusión de los patrimonios del difunto y el heredero, de tal modo que este último debe hacerse cargo no sólo de sus bienes, sino también de las deudas del primero y, de ser necesario, afrontarlas con su propio patrimonio. Es el sistema sucesorio romano más antiguo, formalista y rígido, basado pura y exclusivamente en el vínculo de parentesco civil (agnaticio), por el cual únicamente pueden acceder a ella en calidad de herederos (heredes) los hijos varones del difunto, quedando excluido el derecho hereditario de las hijas mujeres⁽⁴⁾.

2. La sucesión creada por el pretor (bonorum possessio)

El sistema hereditario romano primitivo es en sí mismo injusto, puesto que no contempla el vínculo de parentesco de sangre (cognatio), limitándose únicamente al individuo varón de la familia, excluyendo a la hija mujer. Es el pretor, conocedor de la realidad romana, quien comienza lentamente a paliar las injusticias del primitivo sistema regido por la ley de las XII Tablas, adecuándolo a las necesidades de la sociedad de su tiempo. Así, paralelamente a la herencia (hereditas), surge este tipo de sucesión creada por el pretor, por la cual le otorga al heredero la posesión de los bienes (bonorum possessio). Este nuevo tipo de sucesión nace a instancias del pretor con la finalidad de completar, suplir y corregir la rigidez del derecho civil (ius civile). Es decir que coexisten en Roma dos órdenes sucesorios bien diferenciados: uno primitivo, formalista y rígido, regulado por el derecho quiritarario (ius civile), basado en el parentesco civil (agnaticio), y otro creado por el pretor, que es menos formal y rígido, destinado a suavizar y completar el viejo sistema, introduciendo claramente el vínculo de parentesco de sangre (cognaticio).

Hallamos aquí otro ejemplo de lo dicho respecto del constitucionalismo dogmático romano en cuanto a la incorporación del marginado por el mismo sistema jurídico.

Estudiando detenidamente las fuentes este tipo de sucesión, puede definirse como "el derecho que tiene el heredero designado por el pretor de perseguir y retener el patrimonio o la cosa que fuere del causante". El derecho de posesión debe entenderse no sólo sobre las cosas, sino también sobre un derecho. Esto quiere decir que la posesión de la herencia pretoriana (bonorum possessio) es en sí misma un verdadero derecho a recibir la herencia, aun a espaldas del derecho civil (ius civile), aunque ella no tenga bienes corpóreos, limitándose entonces, en este caso, al simple título de heredero⁽⁵⁾.

I. EL TESTAMENTO (TESTAMENTUM)

Siendo el testamento una creación pura de los romanos, como dijera ut supra, y considerado uno de los negocios jurídicos más importantes y fundamentales de la vida cotidiana, preocupa constantemente a los juristas definirlo, precisarlo, estudiarlo y analizarlo.

II. EL CONCEPTO DE TESTAMENTO EN LAS FUENTES

En primer lugar, Ulpiano, considerado uno de los grandes juristas clásicos, define el testamento como "la manifestación legítima y acreditada de nuestro pensamiento hecha con las solemnidades debidas para que prevalezca después de nuestra muerte"⁽²⁾. Por su parte, su discípulo Modestino lo define como "la justa expresión de nuestra voluntad respecto de lo que cada cual quiere que se haga después de su muerte"⁽³⁾.

Se advierte en ambas opiniones que, si bien precisan notablemente la figura jurídica del testamento, nada dicen respecto de la "institución de heredero", elemento de fundamental importancia en su configuración. Posteriormente, la misma labor de la jurisprudencia romana incorpora lentamente en el concepto de testamento "la institución de heredero" como referente necesario de su validez, con el agregado de otras cuestiones relacionadas con aquél, como confección, perdurabilidad, efectos, etc.

III. LA EVOLUCIÓN DEL CONCEPTO DE TESTAMENTO. CARACTERÍSTICAS

Puede definirse al testamento, por fin, como producto de la culminación en la evolución de la jurisprudencia romana, diciendo que "es la disposición de última voluntad de una persona por la cual nombra esencialmente heredero, manifestada mediante un acto solemne, que puede ser revocable, sin perjuicio de ordenar también respecto de otros aspectos de su patrimonio".

Esto quiere decir que el testamento en Roma presenta las siguientes características a tener en cuenta. Es un acto mortis causa que contiene la decisión del otorgante, o testador, respecto del futuro de su patrimonio. En él, necesariamente debe nombrar uno o varios herederos, contemplando la "figura o institución de heredero" dado que, en caso contrario, el testamento no se considera válido. Una vez otorgado, no es para siempre, sino que puede ser revocado o modificado cuantas veces lo considere oportuno o necesario su autor. Además, no sólo debe designar heredero, sino que también puede contener otras disposiciones referentes al patrimonio o a las personas que se encuentran bajo la potestad del testador, v.gr., legados, manumisiones, designación de tutores, curadores, etc.

IV. LA INSTITUCIÓN DE HEREDERO

Consiste en la designación de sucesor o heredero por parte del testador. Es la cláusula más importante del testamento. En el primitivo derecho testamentario regido por el derecho civil (*ius civile*), la designación de heredero debe encabezar el testamento y efectuarse en términos precisos y en latín, bajo pena solemne de nulidad. Más tarde se admite una mayor flexibilización, por cuanto se le da mayor importancia a la voluntad del testador por sobre las formas. De tal modo, la designación de heredero se puede efectuar en cualquier parte del texto, sin fórmulas sacramentales y en cualquier idioma. Lo que prima fundamentalmente es la voluntad del testador, que debe ser interpretada inequívocamente, prescindiendo de cualquier atadura formal.

V. LAS ACCIONES DEL HEREDERO

El heredero cuenta a su favor con dos acciones de distinta índole para hacer valer su derecho. La primera, originada en el derecho civil, denominada "acción de petición de herencia" (*actio petitio hereditatis*), y la segunda, creada por el pretor, llamada interdicto posesorio (*interdictum quorum bonorum*).

1. La acción de petición de herencia (*actio petitio hereditatis*)

Tiene como fin otorgar al heredero al que se le niega el derecho a la herencia su reconocimiento. Persigue la restitución de los bienes hereditarios con todos los accesorios de quien los posee por cualquier título o derecho. Es una acción de carácter real y universal. Es real, por cuanto, de modo similar a la "acción de reivindicación" (*reivindicatio*), el heredero persigue y reivindica las cosas que conforman la herencia. Es universal, ya que también tiene como objetivo lograr el reconocimiento de la calidad de heredero.

2. El interdicto posesorio (*interdictum quorum bonorum*)

Lo crea el pretor a fin de proteger a los herederos. Tiene como objeto que el heredero adquiera la posesión de las cosas aún no poseídas. Así, el heredero tiene un medio para exigir la entrega de los bienes hereditarios de quien los posee por cualquier título o derecho⁽⁴⁾.

VI. LAS FORMAS DE TESTAR

Conscientes los juristas de la gran importancia del testamento en la vida cotidiana romana, dado que se trata nada menos que de legislar o disponer sobre el futuro de la familia, considera de especial importancia preservar la seguridad de la manifestación de la voluntad del testador. Por ello,

se preocupa entonces de rodear al acto de todo tipo de solemnidades o formalidades que varían y evolucionan con el transcurso del tiempo. En el derecho primitivo tienen gran importancia las formalidades y quizá parezcan hoy excesivas, pero luego, al cambiar la vida en la misma Roma, se modifican, adecuándose, atemperándose e incluso desapareciendo.

La cuestión de las solemnidades o formalidades del acto de testar, en mi opinión, no es otra cosa que la relación que éstas presentan con lo que hoy conocemos modernamente como "Teoría de la Publicidad de los Actos" y su efecto inmediato, "la oponibilidad a terceros", que, como ya sostuve, tienen su origen en el derecho romano.

1. Las formas de testar en Roma y la "publicidad del acto". "La oponibilidad a terceros"

Los juristas romanos tienen en claro que el efecto primordial de todo acto trascendente es su oponibilidad, y para que esto acontezca legalmente, comprenden que el acto en cuestión debe ser necesariamente público o notorio en algún momento. Es decir que el acto debe alcanzar un determinado nivel de conocimiento por parte de la sociedad, que precisamente lo convierte en "dominio de todos". Y una vez que ello se logra, el acto puede ser sostenido por los interesados y éstos pueden oponerlo contra quien pretenda hacer valer un derecho contrario.

Descansa en el mismo derecho romano, como pilar incontrastable, la necesidad de sus juristas de crear los mecanismos necesarios que les permitan a los ciudadanos vivir en forma civilizada, dirimiendo sus conflictos de manera incruenta dentro del orden institucional del Estado. Es precisamente ésta una de las características propuestas en su modo de vida que los diferencia del mundo circundante, denominado a su propio juicio "bárbaro".

La permanente necesidad de crear derecho, cualquiera sea el modo empleado, los lleva a comprender que todo negocio jurídico para trascender, es decir, producir efectos frente a terceros, debe cobrar notoriedad. Ello es, en definitiva, el sentido del moderno "derecho registral". En la actualidad asistimos a su pleno apogeo. Nos encontramos en nuestra vida cotidiana, incluso sin saberlo, registrados. Ello no sólo se refiere a lo que se conoce como "derecho registral clásico", v.gr., Registros de la Propiedad Inmueble, Personas, Propiedad Intelectual, Propiedad Automotor, Prendario, etc., sino también a lo que se puede llamar "nuevas formas de derecho registral", v.gr., toda variante de calificación del individuo según el poder adquisitivo.

La razón filosófico-práctica del registro no es otra que poner en conocimiento del resto de la sociedad que aquello que figura en él es cierto e inobjetable, y por lo tanto puede ser oponible válidamente por los interesados contra quienes pretendan un derecho contrario. Esta última finalidad del derecho registral moderno nace en Roma, es romana, y es una característica del mundo jurídico occidental actual.

Me permito efectuar esta apreciación sobre el tema por cuanto advierto en el estudio del derecho romano la necesidad inmanente de sus juristas de lograr la finalidad de la "publicidad del acto" para ser "oponible" a terceros. He descubierto en el modo de testar romano un claro vestigio de lo expuesto.

2. La evolución de las formas de testar

El derecho romano, con el transcurso del tiempo, brinda distintas formas de testar que se adecuan a las diversas necesidades, conduciéndolas a los modos de testar de nuestro derecho actual. Su evolución debe tratarse durante el derecho quiritarario (ius civile), honorario, posclásico y justinianeo.

3. Las formas de testar en el derecho civil (ius civile). Clases

Son las formas más antiguas, las primeras que se consideran jurídicamente en Roma, adaptadas a los tiempos de paz y guerra. Esto es así, por cuanto el ciudadano romano, señalan las fuentes, puede dejar formalmente testamento en tiempo de paz ante el pueblo reunido en comicio (*testamentum in calatis comitiis*), y durante la guerra ante el mismo ejército (*testamentum in procinctu*)⁽⁵⁾. No es de extrañar este tipo de formalidades, puesto que ambas contemplan el modo de vida y sentir del ciudadano romano en los albores de la República. El transcurso de su vida acontece en el desempeño de sus plenas facultades de ciudadano durante la paz y, al mismo tiempo, se encuentra listo para servir militarmente a Roma durante la guerra. Se advierte, en rigor de verdad, que ambos testamentos descansan en un mismo fundamento, el pueblo. Éste es quien recepciona y anoticia la última voluntad del ciudadano, en un caso, en tiempos de paz reunido en comicios, y en otro, cuando se encuentra militarizado para la guerra. Estas formas de testar son las que considero como las más antiguas en el derecho romano.

Luego surgen durante el mismo período (*ius civile*) las conocidas como "el testamento otorgado por el sistema del cobre y la balanza" (*testamentum per aes et libram*) y el testamento oral ante siete testigos (*testamentum nuncupativum*). Estas dos últimas formas de testar surgen ante la necesidad de cubrir los espacios de vida cuando no pueden hacerlo los dos testamentos anteriores. Así, si un padre de familia necesita modificar o dejar testamento en tiempo de paz y se encuentra fuera de las fechas preestablecidas para ello, se halla en un verdadero problema. Por estos motivos surgen las nuevas formas de testar dentro del mismo *ius civile*.

FRANJA

3.1. El testamento ante los comicios (*testamentum in calatis comitiis*)

Es el modo más antiguo y habitual de testar en tiempos de paz ante el pueblo reunido en comicios. El "jefe de familia" (*pater familias*) manifiesta su última voluntad oralmente ante el pueblo que recepciona y se anoticia para que el acto surta efecto oportuno ante los interesados. En Roma, el pueblo se convoca mediante el comicio. Y es ante éste que el ciudadano romano acude a manifestar su voluntad de modo solemne y para que no quede ninguna duda al respecto, por cuanto el otorgar testamento designando herederos significa el traspaso ordenado de la familia, su continuidad y futuro. En este período, estoy hablando de fines de la Monarquía y primer tercio de la República, la convocatoria para dejar testamento se realiza a través de los comicios curiados. Su estructura y convocatoria se utiliza como depositario de la voluntad testamentaria de los "padres de familia". Dos veces al año estos comicios dejan de funcionar como asamblea deliberativa y pasan a recepcionar los testamentos de los ciudadanos. En esta oportunidad son presididos por el pontífice máximo (*pontifex maximus*), o, en su defecto, por el rey religioso (*rex sacrorum*), y el comicio no se denomina "curiado", sino "calado". Se convocan para estos fines en los meses de marzo y mayo, posiblemente obedeciendo a celebraciones religiosas, no pudiéndose precisar con seguridad la fecha, ya que algunas fuentes hablan del día 15 y otras del día 24. Cuando los comicios curiados comienzan a ser reemplazados por los comicios centuriados y tribados, igualmente conservan la función de recepcionar testamentos. Pero el pueblo, que ya no es convocado para estos comicios, sólo está formalmente representado por treinta *lictors* (funcionarios del Estado), que simbolizan las treinta primitivas curias romanas. La presidencia y dirección del acto continúa en manos del pontífice máximo⁽⁶⁾. Se advierte, una vez más, la finalidad de registrar el acto.

3.2. El testamento ante el ejército en pie de guerra (*testamentum in procinctu*)

Se lleva a cabo oralmente ante el ejército alistado o encuadrado para la guerra. Es menos formal que el anterior, más simple, posiblemente ante la necesidad que genera la proximidad de la muerte

por el riesgo en combate. Los últimos vestigios de este modo de testar se encuentran a fines de la República, desapareciendo prácticamente por completo más tarde⁽⁷⁾.

VII. EVOLUCIÓN DE LAS FORMAS DE TESTAR EN TIEMPOS DE PAZ RECONOCIDAS POR EL DERECHO CIVIL (IUS CIVILE)

Se dijo que los únicos dos modos de testar reconocidos desde el inicio por el derecho civil han sido siempre ante el pueblo, sea en tiempo de paz o de guerra. Pero la practicidad romana pronto advierte que si un ciudadano romano no se encuentra alistado para la guerra tiene por delante casi un año de espera hasta la convocatoria del próximo comicio, tiempo por demás extenso durante el cual no puede dejar legalmente testamento si le acontece un serio peligro de muerte, v.gr., accidente o enfermedad grave, poniendo en dificultades el futuro y la continuidad de su familia, muriendo intestado. Esta última posibilidad origina la aparición práctica de una nueva modalidad de disposición del patrimonio para después de la muerte de su titular mediante la implementación de la denominada "venta familiar" (mancipatio familiae), utilizando el sistema de transmisión de bienes conocido como mancipatio.

1. El testamento por venta familiar (mancipatio familiae)

Este negocio en sí mismo no es un modo de testar, sino claramente la venta o traspaso del patrimonio del testador a una persona de su confianza. El primero vende su patrimonio (familiae pecuniaque) a una persona de su amistad mediante el "procedimiento del cobre y la balanza llevado a cabo ante el libripens y cinco testigos" (mancipatio). Al comprador se lo denomina "adquirente del patrimonio" (familiae emptor) y se comporta como un verdadero heredero, aunque sin serlo, puesto que se obliga a llevar a cabo las liberalidades que el testador le encomienda⁽⁸⁾. Es bueno señalar, según se desprende de las fuentes, que esta nueva modalidad de testar luego comienza a ser utilizada por los plebeyos en un momento en que todavía no tienen convocación comicial. Destaco la practicidad de los juristas romanos, puesto que, al advertir las disposiciones rígidas del derecho civil superadas por la realidad, solucionan el inconveniente con esta nueva "modalidad de disposición del patrimonio" en reemplazo del testamento, considerando al adquirente como una especie de heredero, aunque jurídicamente no tiene dicha condición. Por este motivo, he preferido utilizar intencionalmente la expresión "modalidad de disposición del patrimonio" en lugar de "forma de testar". Esta nueva modalidad pronto evoluciona, adaptándose a nuevas y puntuales situaciones que se suscitan a diario y de las cuales los juristas no pueden sustraerse, como las que siguen.

El testador, por disposición expresa de la ley de las XII Tablas, tiene prohibido vender o traspasar el patrimonio a los hijos que se encuentran bajo su potestad, con lo que la nueva modalidad se torna inocua, dado que siempre es necesario contar con un extraño a la familia. Por otra parte, si el testador supera la crisis de salud, no puede recuperar el patrimonio y dejar sin efecto su traspaso, por cuanto el acto es definitivo. No existe ninguna acción que le permita al testador revocar el acto y recuperar lo que es suyo, quedando esto último, en definitiva, en manos de la honradez y moralidad del adquirente (familiae emptor). Si éste tampoco cumple con las disposiciones del testador perjudicando a los beneficiarios, no se puede hacer nada, por cuanto no existen acciones destinadas a tal fin. El panorama es claro, sólo la probidad y honradez del adquirente (familiae emptor) permite que la voluntad del testador pueda cumplirse, lo que trae más de un inconveniente en la práctica.

2. El testamento mediante el sistema del cobre y la balanza (testamentum per aes et libram)

La jurisprudencia romana soluciona la gravedad del problema adaptando la "modalidad de disposición del patrimonio del testador" denominada familiae pecuniaeque, introduciendo una nueva forma de testar mediante el sistema del cobre y la balanza (testamentum per aes et libram)⁽⁹⁾. Esta forma de testar, bastante compleja por cierto, consiste fundamentalmente en dos partes, la Mancipatio y la Nuncupatio. En primer lugar, el "padre de familia" enajena su patrimonio a un tercero (familiae emptor) mediante la Mancipatio. Este último manifiesta formalmente en el acto que no adquiere la propiedad del patrimonio, sino que lo hace al solo efecto de otorgar el testamento que contiene la voluntad del enajenante, asumiendo la obligación de entregar los bienes a los herederos designados por aquél. En segundo lugar, al mismo tiempo que se celebra el acto de la Mancipatio, se lleva a cabo la Nuncupatio, que consiste en la declaración del "padre de familia" (testador) ante los cinco testigos presentes y portando en sus manos las tablillas enceradas que contienen el nombre del heredero, y las demás disposiciones testamentarias, que ésta es su voluntad. Lentamente, la Nuncupatio se convierte en la parte principal del acto, desplazando al testamento per aes et libram. Es decir que la figura del familiae emptor como heredero figurativo del testador es reemplazada directamente por el heredero designado por éste a través de la Nuncupatio⁽¹⁰⁾.

3. El testamento verbal (testamentum nuncupativum)

La evolución precedentemente expuesta es recepcionada por el ius civile, que lo reconoce de modo autónomo con el nombre detestamentum nuncupativum. Se trata de la declaración verbal de la voluntad del testador formulada directamente ante siete testigos⁽¹¹⁾. Esta nueva forma de testar ofrece indudablemente menos garantías que la anterior (es verbal), pero gana en sencillez y celeridad.

VIII. LAS FORMAS DE TESTAR EN EL DERECHO HONORARIO

El testamento pretoriano. Los pretores trabajan sobre la idea del testamento per aes et libram modificándolo, simplificándolo y adaptándolo a las necesidades cotidianas. De tal modo el derecho pretoriano admite como testamento válido la voluntad del testador formulada por escrito sobre las tablillas enceradas que contienen su firma y selladas por siete testigos, prescindiendo de las demás formalidades del testamento per aes et libram. Esta nueva modalidad le otorga derecho a peticionar la herencia al heredero que presenta las tablillas. El magistrado accede a ello, otorgando la bonorum possessio secundum tabulas⁽¹²⁾.

IX. LAS FORMAS DE TESTAR EN EL DERECHO POSCLÁSICO E IMPERIAL

1. El testamento escrito (testamentarius o tripertitum)

Durante este período se simplifica aún más la forma de testar, haciendo acopio de la evolución y experiencia recogida del viejo sistema y las adecuaciones introducidas por los pretores. El testamento es escrito personalmente por el testador o por un notario o escribano (tabularius) en su nombre sobre pergaminos o papiros. Lleva la firma del otorgante y de siete testigos presentes en el

acto (suscriptio). Después de firmado, es cerrado en presencia de quienes participan en su redacción, procediendo los testigos a sellarlo en la parte exterior (signatio) y firmando nuevamente al lado del sello (superscriptio). Esta forma de testar es, de algún modo, la síntesis de la evolución de las formas enunciadas anteriormente en el derecho civil y pretoriano, tomando lo mejor de ambas, dando origen a lo que en la actualidad se conoce como testamento. Las principales características de este testamento son las siguientes: escritura, firma del testador, presencia y firma de testigos en el acto, privacidad, seguridad mediante la reserva del contenido y garantía de éste a través de los sellos y firmas externas. Precisamente, la denominación "tres partes" (tripertitum) se debe a que contempla las formalidades del derecho civil, pretoriano e imperial. Este último se encuentra presente en la nueva modalidad implementada con la Constitución de los emperadores Teodosio II y Valentiniano III (439), que legisla sobre el tema⁽¹³⁾.

X. LAS FORMAS DE TESTAR EN EL DERECHO JUSTINIANO

Justiniano admite dos tipos de testamentos: por un lado, los conocidos generalmente como "privados y públicos" (privatum et publicum) y, por otro, los denominados "especiales".

1. El testamento privado (testamentum privatum)

Puede ser indistintamente escrito u oral, requiriendo la presencia voluntaria de siete testigos masculinos que deben estar indefectiblemente presentes en el acto. Éstos deben ser ciudadanos idóneos y capaces, es decir, deben poseer "el derecho de instituir o ser instituidos herederos" (ius testamenti factio) y no estar afectados por demencia, sordera, mudez, etc. No se encuentran capacitados para testificar las mujeres, los impúberes, los siervos y los extranjeros.

El testamento escrito puede ser de dos tipos, allografo u "ológrafo". El testamento allografo consiste en que el testador presenta a los siete testigos un pliego no escrito de su puño y letra, declarando que contiene su testamento. El testador y los testigos firman el pliego y, para el caso de que el primero no sepa escribir, debe firmar un octavo testigo en su nombre (suscriptor). Una vez firmado el documento, éste se cierra, y firman y sellan nuevamente su parte exterior. Por su parte, el testamento ológrafo es el que contiene la declaración escrita de puño y letra por el testador, requiriendo la firma de los testigos, aunque no necesariamente del otorgante.

2. El testamento público (testamentum publicum)

Puede ser de dos clases: "judicial" o "ante el príncipe". El "testamento judicial" (testamentum apud acta conditum) es el otorgado en forma pública por el testador ante la autoridad judicial o municipal, que labra un acta al respecto. El "testamento ante el príncipe" (principi oblatum) es el redactado por escrito y entregado al emperador para que lo custodie en sus archivos⁽¹⁴⁾.

3. Los testamentos especiales

Este tipo de testamentos requiere esencialmente requisitos específicos en razón de su propia necesidad, así, los otorgados por militares, en tiempo de peste, el rural, por el ciego, por el sordomudo, por el analfabeto, y el que instituye herederos a sus propios hijos.

4. El testamento militar (testamentum militi)

Es quizá un resabio del primitivo testamento en tiempos de guerra (testamentum in procinctu) regido por el derecho civil. Su finalidad radica en que, por las necesidades y urgencias emanadas del rigor de la guerra y el combate, resulta necesario simplificar los requisitos para otorgarlo en la medida en que quede clara cuál es la última voluntad del militar testador. Por tal motivo, se admite cualquier forma, v.gr., escritura con sangre sobre un escudo o con la punta de una espada en el suelo, etc.⁽¹⁵⁾.

5. El testamento rural (testamentum ruri conditum)

Es el otorgado en lugares aislados, alejados de las ciudades. En este tipo de testamento, al igual que en el anterior, se simplifican los requisitos de otorgamiento en razón de las dificultades que genera el aislamiento y lejanía en que se encuentra el otorgante. Sólo se requiere la presencia y firma de cinco testigos en el acto⁽¹⁶⁾.

6. El testamento otorgado en tiempo de peste (testamentum pestis temporis)

Se simplifican las formalidades en razón de la peste o epidemia, interesando únicamente la voluntad del testador. Por tal motivo, no es necesaria la presencia simultánea de los testigos en el acto⁽¹⁷⁾.

7. El testamento del ciego

Si el testador se encuentra impedido de la visión, puede testar en forma oral o escrita. En el primer caso, dicta el testamento al oficial público (tabularius) y éste lo lee en presencia del otorgante ante siete testigos residentes en la ciudad, que además firman el acta. La falta de oficial público puede suplirse con la presencia de un testigo más. En el segundo caso (escrito), el testamento se lleva previamente confeccionado al oficial público, que lo debe leer en voz alta ante siete testigos, levantando un acta firmada por todos. Se advierte una mayor exigencia de requisitos en mérito a la particular minusvalía física del testador⁽¹⁸⁾.

8. El testamento del sordomudo

En este caso se exige la voluntad escrita de puño y letra del testador para mayor seguridad⁽¹⁹⁾.

9. El testamento del analfabeto

En razón de la ignorancia del testador, se requiere como recaudo la presencia de un testigo más, es decir, ocho en total⁽²⁰⁾.

10. El testamento que instituye herederos a los propios hijos del testador (testamentum inter liberos)

No requiere la presencia de testigos y se debe llevar a cabo por escrito. Además, es necesario que el otorgante escriba de puño y letra el nombre de los instituidos herederos, la cuota que les corresponde y la fecha del testamento. Justiniano dispone especialmente que sólo puede ser revocado por otro testamento regular y solemne⁽²¹⁾.

FRANJA

XI. LA INVALIDEZ DE LOS TESTAMENTOS

La finalidad primordial del testamento es expresar y contener la voluntad del testador respecto del destino deseado de su patrimonio para una vez acontecido su deceso. La jurisprudencia romana considera que el testamento puede estar afectado de invalidez en dos supuestos, a saber: desde el mismo inicio del acto o a posteriori. En el primer caso, el testamento es nulo, y en el segundo, anulable.

Se considera que el testamento es nulo (ab initio) cuando los vicios que lo afectan son de tal envergadura que lo desnaturalizan. Son considerados así cuando los defectos se encuentran en la inobservancia de las formalidades expresamente exigidas por la ley, la omisión de instituir heredero, la falta de capacidad de testar en el causante o para ser nominado heredero por parte del beneficiario.

El testamento puede ser anulado por una causa posterior que lo tiene por roto (ruptum), írrito (irritum) o desierto (desertum).

El testamento se considera "roto" (ruptum) cuando el testador otorga un nuevo testamento que revoca al anterior, o cuando nace un hijo póstumo no contemplado en el testamento original. Se lo llama "írrito" (irritum) cuando el testador cae en esclavitud o es afectado por el postliminio (postliminio) con posterioridad al otorgamiento del acto. Finalmente, el testamento se considera "desierto" (desertum) cuando no existe heredero, ya sea porque se niega a aceptar la herencia, o fallece antes que el testador, o no se cumple la condición bajo la cual se lo nombra⁽²²⁾.

XII. EL LEGADO⁽²³⁾

El ciudadano romano, con más frecuencia el "jefe de familias", utiliza con bastante asiduidad la figura del legado, siendo, por ende, preocupación de los juristas romanos determinarlo jurídicamente. Los primeros en hacerlo son los clásicos Florentino y Modestino. El primero lo hace diciendo "que es una disgregación de la herencia con la que el testador quería que fuera dado a otro algo de lo que en su totalidad habría de ser del heredero"⁽²⁴⁾. El segundo, por

su parte, lo define como "una donación dejada por testamento"⁽²⁵⁾. Acontece que ambas definiciones son consideradas incompletas por los juristas romanos posteriores, y entonces trabajan sobre el particular en búsqueda de una mayor precisión. De la crítica, análisis y evolución de las fuentes en general, puedo decir que el propio derecho romano establece finalmente el concepto del legado, enseñando que es un acto jurídico mortis causa por el cual el testador dispone en el testamento sobre bienes o derechos concretos en forma particular y con cargo al heredero.

1. Las distintas clases de legados

La primera aparición histórica de los legados se remonta al derecho clásico y puedo señalar, tras investigar el tema, que durante el transcurso de dicho período los legados son los siguientes:

1. Legado de derecho real o por vindicación (legatum per vindicationem). El testador utiliza la fórmula "doy y lego", con la cual transfiere al legatario la propiedad de la cosa legada. El efecto se produce a partir del momento en que el beneficiario acepta la herencia, y sólo puede recaer sobre cosas que durante la vida del testador se encuentren bajo su dominio⁽²⁶⁾.

2. Legado de obligación o por damnación (legatum per damnationem). El testador impone al heredero la obligación de cumplir con una prestación. En este caso, el legatario no adquiere la propiedad de la cosa legada como en el caso anterior, sino el derecho de exigir al heredero su cumplimiento. La cosa legada puede encontrarse en el patrimonio del testador o puede ser futura, e incluso puede ser una cosa ajena⁽²⁷⁾.

3. Legado otorgado a modo de permiso o tolerancia (legatum per sinendi modo). Mediante este tipo de legado el testador dispone que el heredero permita y tolere que el legatario se apodere y guarde la cosa legada. En este caso, el legado debe encontrarse siempre bajo el dominio del testador o del heredero, no pudiendo constituirse sobre una cosa ajena⁽²⁸⁾.

4. Legado de preferencia o por precepción (legatum per praeceptionem). Este tipo de legado sólo se otorga en el caso de que existan coherederos, quedando exceptuados los extraños, y no se aplica en la contingencia de heredero único. El beneficiario del legado recibe de inmediato la propiedad de la cosa legada, la que inexorablemente debe encontrarse en el patrimonio del causante⁽²⁹⁾.

2. La evolución en las formas de legar

Las formas de legar anteriormente expuestas presentan, entre otras, las siguientes características, a saber: utilización de fórmulas solemnes y hallarse el legado situado de manera inmediata posterior a la designación de heredero. Ello significa que su constitución es excesivamente formal y cualquier inobservancia produce su nulidad, lo que conlleva, al entender de los juristas romanos, que se avasalla la voluntad del testador, por cuanto ella es sofocada por el rigorismo. Por ese motivo se comienza a evolucionar al respecto, a fin de suavizar las formas, privilegiando sobre éstas la voluntad del testador. Así, cronológicamente, puedo señalar las principales disposiciones tomadas en lo atinente:

Nerón dicta en el año 64 el "Senadoconsulto Neroniano" (Senatusconsultum Neronianum), que dispone que si un legado es considerado nulo por no guardar las formas exigidas para su otorgamiento, igual se lo reputa válido, como si se tratara de un legado de obligación o por damnación (legatum per damnationem). Evidentemente, este senadoconsulto tiene un gran efecto, por cuanto privilegia la voluntad del causante sobre el rigorismo de las fórmulas sacramentales⁽³⁰⁾. A lo largo de casi trescientos años, la preocupación constante de los emperadores y juristas radica en mantener la línea iniciada por Nerón en cuanto a suprimir las formas, haciendo primar la voluntad del testador sobre éstas. Constantino, en el año 339, mediante una Constitución, pone fin a la exigencia de fórmulas solemnes en el otorgamiento de los legados, haciendo prevalecer sobre todo la intención del causante⁽³¹⁾. Finalmente, Justiniano dispone la abolición de todas las antiguas formas de legar, haciendo desaparecer las distintas diferenciaciones respecto de aquéllos, legislando que los legados, a partir de dicho momento, son todos iguales⁽³²⁾.

3. El contenido de los legados

El contenido de los legados es de la más variada índole, abarcando cualquier objeto patrimonial, comprendiendo desde cosas corpóreas, incorpóreas y universales, tales como: derechos reales y crediticios, liberación de deudas y gravámenes, etc. Se los puede agrupar del siguiente modo:

a) Legado genérico (legatum generis). Es el legado indicado por el testador de modo genérico y no concreto, v.gr., cierta cantidad de dinero, maíz, trigo; un esclavo sin especificar cuál, etc.⁽³³⁾.

b) Legado opcional (legatum optionis). Es el legado por el cual el testador le otorga al legatario la opción de elegir una cosa determinada dentro de los bienes que integran la herencia⁽³⁴⁾.

c) Legado de cosa ajena (legatum rei alienae). Es el legado de una cosa que no se encuentra bajo el dominio o propiedad del testador. Consiste, más bien, en una carga impuesta al heredero, quien debe adquirirla para entregársela al legatario y, si no resulta posible, debe abonarle su valor⁽³⁵⁾.

d) Legado de prestaciones periódicas. Por este legado, el testador ordena al heredero que debe entregarle al legatario periódicamente una cantidad de cosas fungibles, por lo general dinero⁽³⁶⁾.

e) Legado de crédito (legatum nominis). El testador cede al legatario un crédito que tiene a su favor contra un tercero⁽³⁷⁾.

f) Legado de débito (legatum debiti). El testador instruye al heredero para que pague una deuda que mantiene con el legatario⁽³⁸⁾.

g) Legado de liberación (legatum liberationis). Es el legado por el cual se libera o se perdona una deuda que el legatario mantiene con el testador⁽³⁹⁾.

h) Legado de alimentos (legatum alimenta). Es el legado por el cual el testador le ordena al heredero entregar periódicamente alimentos al legatario en cantidad suficiente para subsistir⁽⁴⁰⁾.

i) Legado de cuota parte (legatum partitionis). El testador ordena la partición de la herencia entre el heredero y el legatario, ya sea en partes iguales o en cualquier otra proporción⁽⁴¹⁾.

4. La modalidad de los legados

Los legados, como todo negocio jurídico, pueden presentar las distintas modalidades inherentes a este último, tales como: condición, plazo y modo⁽⁴²⁾.

5. El cumplimiento de los legados

Queda supeditado a la validez del testamento en razón de su calidad accesorio respecto de éste. Es decir, el testamento debe cumplir debidamente con la institución de heredero, y éste, además, debe aceptar la herencia. El legado no tiene validez por sí mismo en forma independiente a la institución de heredero y la aceptación por éste de la herencia⁽⁴³⁾.

6. Los modos en que el legatario puede hacer valer su derecho

El legatario tiene a su favor el ejercicio de acciones que le permiten hacer valer su derecho a fin de procurar la adquisición del legado cuando éste le es negado por el heredero o por cualquier otra circunstancia.

Acción de legado (actio legati). Es una acción de carácter personal que tiene la finalidad de exigir al heredero el cumplimiento de la obligación dispuesta en el legado⁽⁴⁴⁾.

Acción de reivindicación (reivindicatio). Acción de carácter real mediante la cual el legatario puede perseguir la restitución de la cosa que perteneció en vida al testador contra quien la tenga al momento de adquirir el legado.

Acción hipotecaria. Es una garantía legal dispuesta por Justiniano que considera gravados con hipoteca todos los bienes de la herencia recibidos por el heredero para garantizar la percepción de los legados. Mediante esta acción se puede ejecutar el legado o su importe⁽⁴⁵⁾.

7. La invalidez de los legados

El legado, al igual que el testamento, es considerado inválido cuando presenta serios defectos que lo tornan impropio. Estas anomalías pueden darse en el mismo momento en que se otorga o con posterioridad. El primer caso torna nulo al legado y no se puede subsanar. Estos defectos se evidencian en la ausencia de las formalidades exigidas por la ley, tales como: falta de aptitud legal para testar; falta de aptitud legal para ser nominado heredero; legar una cosa que no esté en el comercio; la afectación de la voluntad del testador por dolo, error o violencia, etc.⁽⁴⁶⁾. El segundo caso se puede originar por las siguientes razones: revocación del legado, caída del testamento, pérdida de la cosa legada sin culpa del heredero, muerte o incapacidad del legatario antes de que se produzca la aceptación de la herencia por parte del heredero, renuncia del legatario, la adquisición de la cosa legada por el legatario por otra causa, etc.⁽⁴⁷⁾.

XIII. LA EVOLUCIÓN DE LAS RESTRICCIONES IMPUESTAS A LAS FACULTADES DE LEGAR. LA LEX FALCIDIA⁽⁴⁸⁾

Desde antiguo el pater familias posee en Roma amplios derechos para testar. Así lo sostiene la ley de las XII Tablas al ordenar que todo lo dispuesto en el testamento tiene plena validez. Esta facultad, con el correr del tiempo, apareja serios inconvenientes, por cuanto en la práctica el testador puede agotar todo su patrimonio mediante una gran cantidad de "legados" y "manumisiones", dejando nada más que un simple título de heredero, y sin bienes. Por esta razón, los instituidos herederos comienzan a negarse, cada vez en mayor medida, a aceptar la herencia, y buena parte de los "padres de familias" mueren intestados, perjudicando a la familia y al fisco⁽⁴⁹⁾. Para evitar esta anómala situación comienza a gestarse lo que se denomina "política de restricciones a la facultad de testar". En tal sentido, expondré las leyes dictadas en consecuencia, hasta arribar a la más importante de todas, la lex Falcidia, con la cual prácticamente nos encontramos en el inicio de la "legítima".

a) Lex Cincia (204 a.C.). Es una ley, o plebiscito, propuesta por el tribuno Cincio Alimento, que prohíbe dar y recibir donaciones superiores a cierta cantidad, señalando al mismo tiempo quiénes se encuentran exentos de cumplirla.

b) Lex Furia testamentaria (data aproximadamente entre los años 200 y 173 a.C.). Es un plebiscito propuesto por el tribuno C. Furias, que prohíbe disponer mediante legado u otra disposición mortis causa una cantidad superior a mil ases, con excepción de aquellos que benefician a los cognados hasta el sexto grado, y aun hasta el séptimo cuando se trata de un hijo de un sobrino⁽⁵⁰⁾. Pero esta ley no consigue el fin propuesto, dado que aquel que desea burlarla dispone del patrimonio mediante varios legados a distintas personas con la previsión de que no supere cada uno de ellos el mencionado tope. Por esto la cuestión permanece intacta.

c) Lex Voconia (169 a.C.). Plebiscito propuesto por el tribuno Q. Vocanius Saxa, que dispone que los legatarios no pueden recibir como legado mayor parte que el heredero⁽⁵¹⁾. Aunque esta ley se considera un avance comparada con la anterior, tiene un defecto similar. Si el patrimonio se distribuye entre muchos legatarios, la porción del heredero queda tan reducida que ni siquiera alcanza para solventar las cargas de la herencia⁽⁵²⁾.

d) Lex Falcidia (40 a.C.). Ley rogada, o plebiscito, propuesta por el tribuno P. Falcidius, que ordena para todos los casos que los legados no pueden superar las tres cuartas partes de la herencia, de modo tal que al heredero siempre le queda intacta la cuarta parte, recibiendo por dicha causa la denominación de "cuarta falcidia". Esta ley se promulga con la finalidad de subsanar las deficiencias de las dos leyes anteriores. Puedo afirmar que con su sanción prácticamente la jurisprudencia romana se encuentra en camino de gestar "la legítima". Por tal motivo, y dada su importancia, la desarrollaré detenidamente más adelante.

e) Lex Fufia Caninia (2 a.C.). Ley rogada que prohíbe las manumisiones testamentarias que superen determinado número de esclavos.

1. El análisis de la lex Falcidia en particular⁽⁵³⁾

Como he dicho ut supra, esta ley es la más importante de todas, puesto que, a mi entender, origina la legítima⁽⁵⁴⁾. Por tal razón, he de detenerme en su análisis y consideración.

FRANJA

1.1. La finalidad de la ley

He dicho que esta ley dispone que el testador sólo puede legar las tres cuartas partes de su patrimonio. Es decir que le quedaintangible al heredero la cuarta parte de la herencia⁽⁵⁵⁾. Las leyes indicadas anteriormente (Furia Testamentaria, Voconia, Cincia, Furia Caninia) pertenecen a las muchas disposiciones que en Roma se toman dentro del contexto político para evitar los abusos emanados de las facultades de legar y de manumitir por testamento, intentando remediar los desmanes, equivocaciones y falta de previsión cometidos por los testadores, pero que lamentablemente no cumplen con su objetivo. La razón de su ineficacia radica en cuanto a que sus disposiciones se refieren a cada legatario en particular, desprotegiendo al heredero. La lex Falcidia, en cambio, persigue que todos los legatarios reduzcan sus legados en cuanto sea necesario para que al heredero le quede libre "la cuarta parte de la herencia" y no tenga inconveniente en aceptarla. Es evidente que entre las ventajas que provoca figuran la de no morir intestado, y no privar al fisco del impuesto. Así y todo, la lex Falcidia no constituye una solución definitiva al tema, puesto que no se impone a la "voluntad del testador", sino que tiene carácter supletorio. Sólo se aplica cuando el testador no prohíbe expresamente su aplicación, entendiéndose que éste no quiso dejar sin ninguna participación a la persona que le era más querida, el heredero.

1.2. Los beneficios de la ley

Según el texto, únicamente gozan del derecho de peticionar su aplicación los herederos testamentarios, quedando exceptuados los legatarios y fideicomisarios. Estos últimos deben reducir los legados y fideicomisos en proporción al derecho intangible (cuarta parte de la herencia) correspondiente al heredero, con excepción de las manumisiones y los legados de alimentos⁽⁵⁶⁾.

Ningún problema surge si una sola persona es llamada en primer lugar por el testador, o por la ley, pero como la herencia puede fraccionarse en distintas partes, así, legados, manumisiones, etc., y los llamados a heredar pueden ser de distintos grados sucesorios, la lex Falcidia establece minuciosamente distintas posibilidades y situaciones, entre las cuales podemos señalar como más importantes las siguientes: a) si una persona es llamada a recibir diversas porciones de la herencia, deben acumularse todas para computar si exceden en conjunto la porción legal del heredero; b) si varias personas son llamadas a recibir diversas partes de la herencia, cada una debe reducir su parte en resguardo del derecho del heredero; c) en caso de que existan varios herederos y uno de ellos no accede a la herencia, la ley ordena distribuir su parte entre los demás herederos, distinguiendo minuciosamente los supuestos de acrecer (los restantes herederos acumulan la parte que acrecen a la suya, aplicándose luego las disposiciones de la lex Falcidia sobre el total obtenido) y de sustitución (se aplica el principio que el sustituto reemplaza íntegramente al heredero originario, aplicándose "la cuarta falcidia" sobre la acumulación íntegra)⁽⁵⁷⁾.

1.3. Las liberalidades y exclusiones sujetas a la aplicación de "la cuarta falcidia"

La lex Falcidia solamente comprende los legados, cualquiera sea su objeto, extendiéndose su aplicación más tarde a las donaciones mortis causa. Por el contrario, no se aplica a los legados que no disminuyen realmente la herencia; que no constituyen en sí mismos una verdadera liberalidad; que disponen la libertad de un esclavo; los que deben pagarse recíprocamente los herederos; los que recaen sobre fincas cuya enajenación prohíbe el testador; los que contienen cosas que trata de ocultar el heredero; los que se refieren a objetos que el testador compra para su esposa; etc.

1.4. Las pautas de evaluación de la porción hereditaria sobre la cual se calcula "la cuarta falcidia"

El caudal hereditario que debe tomarse de base para calcular la "cuarta falcidia" es el patrimonio íntegro del causante al momento de su fallecimiento. Resultan ventajas o perjuicios para el heredero todos los aumentos o disminuciones que acontezcan con posterioridad⁽⁵⁸⁾. Los objetos se estiman por su precio real. Se considera integrante del patrimonio del testador lo que el heredero le adeuda y todos los demás créditos que tenga a su favor al momento de su muerte, aunque el difunto los hubiera adquirido bajo condición, estimándose aquéllos por el valor real. De la suma total se deducen las deudas del fallecido, aun las que sean a favor del heredero; el precio de los esclavos manumitidos mortis causa o que por disposición del magistrado deban salir del patrimonio, y los gastos invertidos en el funeral y en la sepultura del testador.

1.5. El cálculo del valor de las liberalidades

El valor de las liberalidades sujetas a la aplicación de la cuarta falcidia se calcula por el que tienen en el mercado al momento de fallecer el testador⁽⁵⁹⁾. Esto es así de sencillo cuando se trata de legados puros y únicos, cuyos objetos han de ser entregados, pero no es tan fácil valuarlos cuando falta alguna de estas cualidades. Al respecto, la ley determina, entre otros, los siguientes supuestos: a) En los legados a término debe deducirse el importe del interés por el tiempo transcurrido desde la entrega; b) En los legados bajo condición debe efectuarse igual deducción que la anterior por el tiempo que transcurre hasta que se cumpla la condición, pero como se ignora en qué momento se cumplirá, y aun si se llega a cumplir, no se toma en cuenta para la aplicación de la cuarta falcidia, sino que los legatarios restantes dan caución al heredero por lo que hubieran recibido de más en caso de ser válidos; c) En los legados de prestaciones periódicas (alimentos, entrega de

sumas de dinero) se distingue si éstos deben considerarse jurídicamente como una o varias liberalidades. En el primer supuesto, se considera a la primera cuota como un legado puro y a las posteriores a término. En el segundo caso indica la grave dificultad de saber a cuántos plazos sobrevivirá el legatario, quedando el legado sujeto a ello; d) Finalmente, en los legados de renta no vitalicia se capitaliza el importe del legado en la valuación general de todos ellos al 4 % anual y las pensiones se reducen en la misma proporción en que se haya deducido el capital para aplicar la "cuarta falcidia".

1.6. Lo que recibe el heredero en concepto de "cuarta parte"

El heredero recibe la parte de la herencia que le queda libre después de cumplir con todas las liberalidades hechas por el testador, y los legados y fideicomisos que no tienen cumplimiento porque los retiene en calidad de heredero. En cambio, no se le imputa al heredero lo que recibe por título de legado, o por cualquier otro concepto que no sea la herencia; lo que recibe del testador por acto inter vivos, siempre que no se lo entregue a cuenta de la cuarta falcidia; los beneficios que el heredero se proporciona por sí mismo, v.gr., la venta de la herencia por un precio ventajoso, transacción efectuada por los acreedores, etc.

1.7. El cálculo de deducción de las liberalidades para completar la "cuarta falcidia"

Cuando al heredero no le queda libre la porción hereditaria dispuesta por la ley, es decir, la cuarta parte del acervo hereditario al momento del fallecimiento del testador, a pesar de las disposiciones legales precedentemente expuestas, se deben disminuir "a prorrata" las liberalidades sujetas a la aplicación de la *lex Falcidia*, teniendo en cuenta las siguientes pautas: a) si la cosa legada es divisible, el heredero retiene su parte correspondiente o la reivindica del legatario, si éste la posee; b) si la cosa legada es indivisible, no se entrega al legatario mientras no le pague al heredero el valor estimativo de su parte; c) si el legado es de prestaciones periódicas, el heredero descuenta de cada entrega la parte proporcional que le corresponde. En este caso, como el legatario puede vivir más o menos años que los que supuso para calcular el valor de la liberalidad, todos los interesados necesitan garantizarse recíprocamente⁽⁶⁰⁾.

1.8. Cuándo no se aplica la *lex Falcidia*

No tiene aplicación en los siguientes supuestos: por voluntad del testador; en los testamentos y codicilos otorgados militarmente; si el heredero no formaliza el inventario; por renuncia expresa o tácita del heredero, pagando o comprometiéndose a pagar íntegros los legados⁽⁶¹⁾.

1.9. Consideraciones respecto de la *lex Falcidia*

Evidentemente esta ley es un verdadero adelanto en la legislación romana, permitiendo poner coto a las ilimitadas facultades del testador que, mediante legados y manumisiones indiscriminadas, coloca en ciertos casos realmente en peligro el acervo del heredero. Este último muchas veces se encuentra prácticamente con una herencia vacía después de cumplir íntegramente con la voluntad

del testador, no restando casi nada para él. Esto trae la paradoja del rechazo a aceptar la herencia, privándose el fisco de percibir el impuesto. De allí que, fracasadas otras leyes anteriores destinadas a solucionar estos problemas, surge la *lex Falcidia*, dando fin a los excesos que comete el testador. La bien llamada cuarta falcidia, con sus puntuales limitaciones y precisiones, trae cordura al sistema, cumpliéndose la voluntad del testador y respetando una porción legítima para el heredero, quien favorecido por ésta, lleva a cabo lo ordenado por el causante, sabiendo que se le respeta el derecho sobre el acervo hereditario, y además el fisco regulariza la percepción impositiva. La *lex Falcidia* es recogida en las *Institutas de Gayo* y en la obra compiladora de Justiniano, contribuyendo con el esclarecimiento equitativo en la moderna tendencia del derecho sucesorio, con gravitación institucional en gran parte de las legislaciones actuales.

XIV. LA LEGÍTIMA(62)

Nace la legítima en el derecho romano como culminación de un largo proceso de evolución en materia sucesoria a partir de las limitaciones a la libertad de testar. Su fin es contemplar el derecho del heredero forzoso o necesario que sin motivo alguno es dejado de lado en el testamento. La legítima se decanta mediante el paso del tiempo desde el propio derecho romano, pasando a las distintas legislaciones modernas, receptada luego en los códigos modernos, como en nuestro caso el Código de Vélez Sarsfield. La importancia de su estudio radica no sólo en conocer sus orígenes, sino que permite comprender mejor la fina sensibilidad del jurista romano que, ante la desprotección sin justa causa del heredero forzoso, le brinda solución jurídica adecuada en salvaguardia de sus legítimos derechos.

XV. LAS LIMITACIONES A LA LIBERTAD DE TESTAR. CONSIDERACIONES SOBRE LA NATURALEZA JURÍDICA DE SU DENOMINACIÓN

Se ha visto precedentemente cómo el poder absoluto del testador en los orígenes de Roma pronto es sometido a restricciones que moldean un nuevo sistema sucesorio, contemplando la necesidad de protección a los herederos más cercanos aquél.

Estas limitaciones provocan dos efectos: 1º) Que el testador pierda su ilimitada libertad para designar heredero a quien quiera. 2º) Que disponga libremente del patrimonio. La primera de las limitaciones indicadas, en mi opinión, debe denominarse "limitación de carácter formal"; y la segunda, "limitación de carácter material". Los juristas romanos, por supuesto, no acuñan estas denominaciones, aunque conocen y aplican a la perfección sus conceptos.

Estimo que estas denominaciones resultan más atinadas que las tradicionales originadas en la pandectística alemana, que las denomina respectivamente "sucesión necesaria formal" y "sucesión necesaria material", dado que si bien la primera presenta un marcado carácter formal, y la segunda sustancial, no es apropiado llamarlas "necesarias". Esto se debe a que la denominada "formal" no obliga necesariamente al testador a nombrar a determinado heredero, sino a que lo designe o le niegue dicha designación. Por su parte, en la llamada "material", el beneficiario no es forzosamente sucesor en el verdadero sentido de la palabra, lo cual apareja equivocaciones y errores de enfoque en el tema.

No obstante ello, la doctrina romanista mayoritaria ha continuado tradicionalmente con estas denominaciones, lo cual no comparto, optando por llamarlas, entonces, "limitaciones de carácter formal" y "limitaciones de carácter material", por cuanto, en sí misma, la legítima nace en Roma exclusivamente como una limitación a la facultad de disposición del "padre de familias", y no precisamente como un derecho del heredero. Además, debo destacar que la denominación tradicional no obedece a un fundamento de la jurisprudencia clásica, sino a una necesidad moderna recogida por la pandectística alemana. El jurista romano clásico considera a la legítima como una verdadera limitación al poder del padre de familias, y no como un derecho del heredero. Por esto, a mi juicio, las denominaciones "limitación de carácter formal" y "limitación de carácter material" son mucho más apropiadas que "sucesión necesaria formal" y "sucesión necesaria material".

1. Las limitaciones de las facultades de testar de carácter formal

En principio, para tratar correctamente el tema y lograr una mejor comprensión, habré de hacer hincapié necesariamente en la institución de designación de heredero y su desheredación obligada por el padre de familias. Esto conduce a tratar el tema en su evolución a través de los derechos civil, pretoriano y justiniano.

1.1. La cuestión en el derecho civil

El antiguo *ius civile* fija el principio de que el testador no puede dejar de mencionar en el testamento a los "herederos suyos" (*heredes sui*), ya sea instituyéndolos como herederos o desheredándolos, puesto que por una simple omisión no se los puede considerar excluidos de la herencia⁽⁶³⁾.

Cuando se trata de hijos varones, éstos deben ser instituidos o desheredados nominativamente, si no el testamento se considera nulo y se debe abrir la sucesión *ab intestato*, aun para el supuesto en que el hijo falleciera antes que el causante⁽⁶⁴⁾.

Las hijas, nietos, nietas y otros descendientes pueden ser desheredados también nominativamente, y además en forma conjunta⁽⁶⁵⁾. Los efectos en este caso son bien diferentes al anterior. Si el preterito u omitido es un hijo varón, el testamento es considerado nulo, como se dijo más arriba, y se abre la sucesión *ab intestato*. En cambio, cuando se trata de las hijas, nietos de ambos sexos u otros descendientes, el testamento es rectificado, concurriendo el heredero omitido juntamente con los instituidos, no acarreado su nulidad, debiéndose efectuar la siguiente distinción: en el caso de que la omitida sea una hija y se haya instituido herederos a otros hijos varones, aquélla concurre en una parte similar a éstos. Por el contrario, si la hija concurre con herederos extraños que han sido instituidos, lo hace en una mitad, restando la otra parte a estos últimos⁽⁶⁶⁾. El otro supuesto contemplado por el derecho civil es el del "hijo póstumo" (*póstumo sui*). Su omisión provoca la caducidad del testamento y la apertura de la sucesión *ab intestato*⁽⁶⁷⁾. La razón radica en que dichos herederos póstumos no pueden ser desheredados anticipadamente⁽⁶⁸⁾. Los *postumi sui* son aquellos que ingresan bajo la potestad paterna después de que éste otorgue testamento, ya sea por nacimiento, adopción o adrogación. Es necesario recordar que la jurisprudencia romana admite diversas clases de póstumos, a saber: a) Legítimos (*Legitimi*). Son los nacidos después de la muerte del testador. b) Aquilianos (*Aquilianii*). Son nacidos también después de la muerte del testador, pero son descendientes de un hijo predifunto. c) Veleyanos o Junianos (*Velleiani* o *Juniani*). Son los nacidos después de la confección del testamento. d) Cuasi Veleyanos (*Quasi Velleiani*). Los que adquieren la condición de *sui* después de la confección del testamento. e) Julianos o Salvianos (*Juliani* o *Salviani*). Son los que nacen y se vuelven *sui* después de otorgado el testamento por la premuerte de un hijo del testador (*filius familia*).

1.2. La cuestión en el derecho pretoriano u honorario

Aun así y todo, el sistema regido por el *ius civile* no es perfecto y deja afuera a los hijos emancipados, quienes quedan excluidos del testamento ante su simple omisión. El pretor acude en su protección complementando al *ius civile* con la finalidad de dar prevalencia a la familia cognaticia sobre la agnaticia.

El nuevo sistema propuesto por el derecho pretoriano es la consecuencia de las reformas propuestas por el pretor en su "Edicto", cuando crea la *bonorum possessio unde liberi*, equiparando

en grado sucesorio a los herederos sui con los hijos emancipados⁽⁶⁹⁾. De allí que necesariamente deba reformarse el sistema sucesorio, fijando las siguientes reglas:

a. Los hijos varones emancipados deben ser designados herederos o desheredados en forma nominativa. Si el hijo varón emancipado es omitido en el testamento, éste conserva su validez hasta tanto el omitido lo ataque de nulidad, con lo cual cae la institución de heredero, ya que el pretor le otorga la *bonorum possessio contra tabulas*. Esta última acción sólo afecta las porciones hereditarias, ya que el heredero omitido y el heredero instituido la dividen como si se tratara de una sucesión *ab intestato*; pero en cuanto se refiere a legados, manumisiones, desheredaciones, dotes, etc., dispuestas en el testamento, conservan su valor⁽⁷⁰⁾.

b. Las hijas emancipadas, por su parte, también deben ser instituidas, o desheredadas en el testamento, pero a diferencia de los hijos emancipados varones, pueden serlo nominativamente o en conjunto. Los efectos son similares a los del hijo varón emancipado y entran en vigor cuando la hija acude al amparo del pretor, quien también le otorga la *bonorum possessio contra tabulas*⁽⁷¹⁾. Esta acción debe ejercitarse dentro del año de la delación de la herencia, ya que una vez que expira dicho plazo, el testamento no objetado conserva todo su vigor. Es de destacar que si el *liberi* fallece antes que el testador, los descendientes de aquél no pueden interponer la *bonorum possessio contra tabulas*, de lo que se infiere el carácter personal de esta acción.

1.3. La cuestión en el derecho justiniano

Si bien la reforma definitiva del sistema sucesorio legitimario es realizada por la Novela 115, con anterioridad a ella Justiniano, mediante una Constitución del año 531, establece que todos los descendientes agnados de nacimiento que se encuentren bajo potestad o emancipados, póstumos o nacidos antes de dictado el testamento, sin distinción de sexos ni de grados, deben ser instituidos o desheredados en forma nominativa, y en el orden en que son llamados en la sucesión *ab intestato*. Para el supuesto de que no se contemple lo expuesto, el resultado de la omisión trae consigo la anulación del testamento si el omitido es un heredero sui; en cambio, si se trata de un hijo o hija emancipados, tiene lugar la *bonorum possessio contra tabula*⁽⁷²⁾.

1.3.1. La Novela 115

La definitiva reformulación y complementación del sistema legitimario romano la concreta el emperador Justiniano mediante la denominada Novela 115 (año 541). En ella se establece que el padre, la madre y los ascendientes paternos y maternos tienen la obligación de instituir a sus descendientes en el orden en que ellos son llamados a la sucesión *ab intestato*, sin que importe que les otorguen legados o fideicomisos, por más importantes que éstos sean.

Dispone también que estos herederos no pueden ser desheredados sino sólo en el caso de ser considerados "culpables de ingratitude" hacia la persona del testador. Determina como causales de ingratitude que el testador debe indicar expresamente en el testamento, entre otras, el atentado a la vida, la injuria intolerable, la acusación criminal, etc.

El heredero instituido debe probar a su vez la certeza de la causal invocada en el testamento bajo pena de considerarlo inválido. Si acontece esto último, se produce la invalidez de la institución de heredero y se abre la sucesión *ab intestato*. Por el contrario, se mantienen plenamente válidas todas las restantes disposiciones testamentarias, v.gr., nombramientos de tutores, manumisiones, legados, fideicomisos, etc.

La Novela 115 legisla también sobre la institución y desheredación de los herederos de los ascendientes del testador, estableciendo que los hijos tienen la obligación de instituir como herederos a sus ascendientes en el orden en que son llamados en la sucesión *ab intestato*. Los ascendientes no pueden ser desheredados por el testador si no media alguna de las causales de ingratitude establecidas en la citada Novela. Ellas también deben indicarse expresamente en el

testamento y ser probadas por el heredero que se instituye en él. En caso contrario, el testamento es nulo en cuanto a la institución de heredero y los ascendientes excluidos son llamados a heredar mediante la sucesión ab intestato.

1.3.2. Las consecuencias jurídicas derivadas de la Novela 115

La Novela 115 establece dos importantes consecuencias jurídicas: 1º) Los descendientes y ascendientes legítimos son considerados herederos y, como tales, reciben su parte. 2º) Las causales de desheredación u omisión se limitan taxativamente a las contempladas en el texto, siendo diferentes para unos y otros.

1.3.3. Las causales de desheredación impuestas a los descendientes por la Novela 115

Para los descendientes dispone las siguientes causales de desheredación: 1. Si pone las manos sobre sus ascendientes. 2. Si infiere injurias graves y deshonrosas contra ellos. 3. Si los acusa en causa criminal, salvo que sea a favor del Príncipe o el Estado. 4. Si es malhechor o convive con malhechores. 5. Si atenta contra la vida de sus ascendientes con veneno o de cualquier otro modo. 6. Si el hijo mantiene contacto sexual con su madrastra o con la concubina de su padre. 7. Si el hijo delata al padre y con esto le acarrea un grave quebranto. 8. Si el hijo no quiere pagar una fianza a su ascendiente para que obtenga la libertad. 9. Si el descendiente prohíbe a su ascendiente que deje testamento para perjudicar a otros posibles herederos. 10. Si contra la voluntad de sus ascendientes el hijo se relaciona con atletas o mímicos y se dedica a estas profesiones, salvo que sus ascendientes ejerzan la misma profesión. 11. Si el ascendiente quiere darle marido a una hija o a su nieta, dotándola incluso a tales efectos, y ella no quiere aceptarlo, prefiriendo llevar una vida lujuriosa. 12. Si alguno de los descendientes padece de insania momentánea y sus descendientes no le prestan la atención y cuidado necesarios. 13. Si el ascendiente cae en cautiverio como prisionero de guerra y sus descendientes no hacen lo necesario para rescatarlo. 14. Si el descendiente no profesa la misma fe católica que su ascendiente.

1.3.4. Las causales de desheredación impuestas a los ascendientes por la Novela 115

Por otra parte, las causales de desheredación que afectan a los ascendientes son las siguientes: 1. Si entregan al descendiente para que pierda la vida, salvo causa legal justificada. 2. Si atacan contra la vida del descendiente mediante veneno, maleficios o cualquier otro modo. 3. Si mantiene contacto sexual con su nuera o la concubina de su hijo. 4. Si le prohíbe al hijo testar perjudicando a otros posibles herederos. 5. Si el padre atenta contra la vida o la salud de la madre o viceversa, o ambos entre sí. 6. Si el hijo padece momentáneamente de locura y los padres no cuidan de él. 7. Si los hijos caen en cautiverio y los padres no procuran su libertad o pagan menos de lo estipulado y muere a causa de ello. 8. Si los padres no profesan la misma fe católica que el hijo.

De igual modo que "la falta de cumplimiento de los requisitos formales" aparea la caída de la institución de heredero, también produce lo propio "la omisión o desheredación injustificada de éste".

La limitación de las facultades de carácter sustancial experimenta una larga evolución. Comienza como una reacción moral o de repudio de la sociedad romana ante el proceder de ciertos "padres de familias" que no destinan en sus testamentos una parte del acervo hereditario a aquellas personas unidas a él por lazos íntimos de parentesco. Esta actitud es mal vista y comienza a considerarse injusta.

A fines de la República, los juristas romanos inician lentamente la paliación de la cuestión, buscando favorecer a los parientes consanguíneos del testador, basándose en el principio de la ausencia del "deber de afecto" (*officium pietatis*). Consideran que incurre en esta falta quien en su testamento omite, deshereda o instituye heredero en escasa porción a un familiar directo. Esta anomalía torna inoficioso al testamento (*inofficiosum*) y le asiste a la persona perjudicada el derecho de impugnarlo⁽⁷⁴⁾. No tiene fundamento en el privilegio de la familia sobre los bienes sino en consideraciones de piedad. No persigue la unidad o hidalguía de la familia sobre la base de la primogenitura, como en el derecho germánico ("reserva familiar"), sino asegurar a los parientes más próximos del difunto una equitativa participación en sus bienes y un digno sustento. Es decir, intenta garantizar la unidad y dignidad de la familia como producto de una nueva conciencia social fundada en la equidad, el afecto y la valoración de la familia de sangre. Es precisamente a fines del período republicano, con el auge del refinamiento de las costumbres y la labor de los jurisconsultos, que se llega a admitir que si un testador omite o deshereda injustificadamente a sus hijos, éstos pueden atacar el testamento de "inoficioso", considerando al testador como "falto de su sano juicio" al momento de otorgarlo. Esto último es una "ficción legal" creada por los pretores para acudir en defensa de los injustificadamente desheredados.

Corresponde entender en estos casos al Tribunal de los Centunviros, que en principio es el único que debe abocarse a estas cuestiones. La acción que los herederos afectados injustamente pueden entablar se llama "querella de inoficiosidad" (*querellainofficiosi testamenti*). Esta acción se funda en la consideración de que el testador no se halla en su sano juicio en el momento de otorgar el testamento. Ello consiste precisamente, según he dicho, en una "ficción legal" creada por los juristas romanos con el fin de paliar equitativamente las injusticias que se presentan a su estudio y consideración. Se trata de una "ficción necesaria", por cuanto considera al testador como "falto de su sano juicio", lo que aparea automáticamente la nulidad del acto ante el vicio que afecta su capacidad. De tal modo, provocada jurídicamente la caída del testamento, se pueden acoger los legítimos derechos de los herederos injustificadamente desplazados o preteridos.

El medio adecuado para lograrlo es la denominada "acción de inoficiosidad", mediante la cual el interesado persigue judicialmente ser reconocido como omitido o desheredado sin causa, provocando la nulidad total o parcial del testamento. El interesado (querellante) tiene la carga de la prueba para que la acción prospere, es decir, probar que ha sido omitido o desheredado injustamente. El judicante (Tribunal de los Centunviros, en un principio) tiene la facultad de apreciar libremente las consideraciones, motivos y proceder del testador, y las razones esgrimidas por el querellante al atacar el acto.

XVI. LA "QUERELLA DE INOFICIOSIDAD". CONCEPTO. EVOLUCIÓN

Puede ser definida como "la acción que faculta a los parientes próximos del testador injustamente desheredados u omitidos a perseguir la declaración de nulidad del acto, fundada en la ficción de la falta de capacidad del testador con el fin de lograr la apertura de la sucesión *ab intestato*".

La "querella de inoficiosidad" tiene origen, como se ha visto, en el derecho clásico, evolucionando luego durante el período posclásico y, más tarde, en el derecho justiniano. Veamos, entonces, dicha evolución.

1. La "querella de inoficiosidad" en el derecho clásico

Esta acción se inicia como producto de la labor jurisprudencial del pretor a fines del período republicano. Pueden ejercerla los descendientes y ascendientes sin distinción (agnados y cognados), lo cual permite inferir que es una acción de ejercicio amplio. De tal modo, el hijo emancipado puede también atacar el testamento de su padre, y viceversa. El testamento de la madre puede ser atacado por el hijo, y a la inversa. Los hermanos, sin distinción de sexo, pueden ejercer la "querella" para atacar el testamento sólo en el caso de que el testador designe heredero a una persona de profesión indigna, v.gr., gladiador.

Para el ejercicio de la "querella", los parientes que se acogen a ella deben cumplir los siguientes requisitos: a) Tener el derecho de ser heredero ab intestato del difunto con grado de legítimo o forzoso. b) No debe mediar causal legítima de desheredación, porque de existir alguna, y si el testador la consigna, el desheredado no tiene derecho que lo ampare. c) El pariente desheredado no debe tener a su alcance ningún otro medio legal para lograr hacer valer su derecho, dado que la querella tiene carácter excepcional y sólo debe acudir a ella como última ratio.

También debe dejarse en claro que en la práctica cotidiana el fundamento de aplicabilidad de la "querella" apareja el inconveniente de que si el testador, a fin de evitar que alguno de sus herederos la interponga, le testa una parte de la herencia, generalmente inferior a lo que le corresponde como heredero ab intestato, corresponde entonces al Tribunal de los Centunviro determinar si la herencia es "lo suficientemente significativa" como para anular el derecho a interponer la "querella". Esto quiere decir que ésta sea "justa" o "ajustada a derecho", es decir, que cubra o alcance para cubrir la cuota legítima ab intestato.

El sistema aludido presenta el reparo de que el testador nunca tiene la plena seguridad de estar procediendo de acuerdo a derecho, pese a requerir el asesoramiento de algún jurista, por cuanto no existe un criterio establecido acerca del Quantum de dicha porción hereditaria. En definitiva, el Tribunal de los Centunviro tiene la última palabra cuando debe entender en la "querella", y lentamente toma cuerpo la idea de que la porción hereditaria, para ser justa, debe alcanzar "la cuarta parte de los bienes que al heredero le hubieran correspondido mediante la sucesión ab intestato". Con el tiempo, esta porción comienza a llamarse "legítima" y más comúnmente "cuarta legítima". Los herederos que tienen derecho a interponer la "querella" reciben después el nombre de "legitimarios". Al llegar a este punto resulta necesario aclarar que si bien el Tribunal de los Centunviro comienza a acuñar los términos indicados ("legítima", "cuarta legítima" y "legitimarios"), no dispone su inmediata aplicación de oficio, sino siempre a instancia del propio interesado cuando considera que no está satisfecha su expectativa hereditaria, debiendo interponer la "querella de inoficiosidad testamentaria" (querella inoficiosi testamenti) para que se cumplan los recaudos del "deber de afecto" (officium pietatis), atacando el testamento, haciéndolo caer, para producir la apertura de la sucesión ab intestato.

En otras palabras, a través de la "querella" no se persigue la aplicación inmediata de la "legítima", sino la caída del testamento y, tras ello, la apertura de la sucesión ab intestato. Finalmente, la jurisprudencia clásica de fines de la República interpreta que es "justo" o "legítimo" respetar al heredero una "cuarta parte del acervo hereditario del testador".

1.1. El cálculo de la "cuarta legítima"

Se manejan distintas pautas para determinar el cálculo de la "legítima", sin perjuicio de advertir que en su determinación surgen pautas comunes con la lex Falcidia (40 a.C.), que dispone la creación de la denominada "cuarta falcidia". Para determinar la "cuarta legítima" se evalúa, en primer término, todos los bienes del testador al momento de su fallecimiento, incluyendo las donaciones, cualesquiera sean sus motivos. A continuación se deducen las deudas contraídas, los esclavos manumitidos testamentariamente y los gastos funerarios, con lo que se obtiene el "acervo hereditario neto". La "legítima" consiste precisamente en "la cuarta parte del acervo hereditario neto", es decir, "la cuarta parte del total de los bienes del difunto deducidas sus deudas". La "cuarta legítima" se aplica por grado hereditario, correspondiendo su distribución proporcional entre todos los herederos legítimos que revisten el mismo grado. De este modo, si existe un solo heredero, a éste le corresponde la totalidad de la cuarta legítima, y si hay varios que tienen el mismo grado, se la divide proporcionalmente entre todos. También la "cuarta legítima" es personal y no es

susceptible de acrecentamiento entre los restantes herederos. Si estos últimos son varios y algunos de ellos se ven privados de acceder a la "legítima" por alguna causal de desheredación, los otros no pueden aumentar sus partes.

1.2. La extinción de la "querella de inoficiosidad"

Como ésta es una acción de carácter real, por ende se extingue en los siguientes supuestos, a saber: si el heredero no la ejerce en el plazo de cinco años después de adir la herencia; si el heredero fallece sin haberla interpuesto; si el heredero renuncia expresamente a interponerla; si el heredero acepta una donación o legado que se le otorgue mediante el testamento.

1.3. Los efectos de la "querella de inoficiosidad"

Una vez interpuesta la "querella" en tiempo propio y mediante los recaudos exigidos, el heredero que recibe una sentencia favorable del tribunal logra que caiga el testamento, anulándose todas sus disposiciones, incluidos los legados, manumisiones y fideicomisos, y se produce la apertura de la sucesión ab intestato. El heredero demandante tiene entonces acceso a ella en carácter de heredero legítimo. Si la sentencia es desfavorable, el heredero es castigado con la pérdida de las liberalidades que el testador le ha dejado, manteniéndose la validez del testamento atacado y de todas sus restantes disposiciones. El fundamento se debe a que su reclamo causa injuria a la persona del testador al sospechar que no goza de sus plenas aptitudes mentales. Es bueno recordar que justamente la "querella de Inoficiosidad" se funda en la "ficción legal" de considerar "demente" al testador por haber dejado fuera del testamento a sus herederos forzosos.

2. La "querella de inoficiosidad" en el derecho posclásico. La "acción en complemento de la legítima" (Actio ad supplendam legitimam)

Durante este período, el esquema general de la "querella" continúa desarrollándose dentro de las pautas indicadas precedentemente, pero con las siguientes modificaciones: a. Se extiende su campo de aplicación a las donaciones excesivas. b. Se produce la aparición de una nueva acción denominada "acción en complemento de la legítima" (actio ad supplendam legitimam).

La primera de las innovaciones indicadas permite a los herederos afectados por el uso excesivo de liberalidades inter vivos que comprometen su derecho a atacarlas por "inoficiosas". Los emperadores y sus juristas, mediante la imposición de "constituciones imperiales", son quienes dedican especial interés a este asunto. Así, Alejandro Severo es el primero que hace lugar al uso de la "acción de inoficiosidad de las donaciones" (querella inofficiosae donationis) para atacar como inoficiosas las donaciones inter vivos que importan una afectación en los derechos del heredero legítimo⁽⁷⁵⁾. Constantino extiende la aplicación de la "querella" a los casos de dotes excesivas (querella inofficiosae donationis vel dotis).

La segunda de las novedades introducidas en el Bajo Imperio, denominada "acción en complemento de la legítima", se debe como respuesta a una nueva modalidad impuesta por los testadores que no instituyen a sus hijos en calidad de herederos, pero a cambio les destinan donaciones en el testamento, con la variedad de que si estas últimas no alcanzan a cubrir el monto de la legítima, ella debe completarse a través del arbitraje de un hombre probo. Esta práctica se generaliza en la sociedad romana de la época, lo que lleva a que en el año 361 una constitución de los emperadores Juliano y Constancio disponga que, presentado este caso, hay que respetar la decisión del testador y no se puede atacar de inoficioso el testamento. A cambio se ordena la

creación de la "acción en complemento de la legítima", que reemplaza a la "querella de inoficiosidad". Mediante esta nueva acción se persigue mantener la decisión del testador, pero dotando al legitimario del derecho a exigir por medio del "arbitraje de un hombre honrado" que se complemente la faltante de su cuota legítima hereditaria⁽⁷⁶⁾. Con el tiempo se extiende esta decisión a casos de constitución de excesivas dotes.

Arribado a este punto, me encuentro en condiciones de brindar las principales características de la "acción en complemento de la legítima" (actio ad supplendam legitiman). Es una acción personal; complementa el testamento y no lo hace caer; es perpetua, puesto que carece de plazo para interponerse y pasa a los herederos; si el legitimario que la ejerce pierde el juicio, no se lo priva del goce de las otras liberalidades recibidas en virtud del testamento.

3. La "querella de inoficiosidad" en el derecho justinianeo

El emperador Justiniano, empeñado en su cometido de reformar jurídicamente el imperio, decide en el año 528 confirmar la resolución de los emperadores Juliano y Constancio (361), y ordena que el legitimario sólo puede ejercer la "acción en complemento de la legítima", y no la "querella de inoficiosidad", aun en el caso de que el testador no disponga la cláusula del "árbitro probo"⁽⁷⁷⁾. También establece como imputable a la legítima la donación inter vivos efectuada por cualquiera de los padres al hijo para adquirir un puesto en el ejército.

FRANJA

XVII. LAS NOVELAS 18 Y 115

Las Novelas 18 (año 537) y 115 (año 541) constituyen las reformas de mayor significado que introduce Justiniano al sistema de la legítima, disponiendo lo siguiente: a. En el testamento se debe dejar constancia expresa de las causales de desheredación por parte del testador respecto de sus herederos legítimos. b. Las causales de desheredación se encuentran legisladas y sólo éstas pueden ser invocadas por el testador. c. La porción correspondiente a la legítima está sujeta a variaciones de acuerdo con el número de hijos, de tal modo que si el testador posee hasta cuatro hijos, la legítima correspondiente asciende hasta un tercio del acervo hereditario que le corresponde en la sucesión ab intestato; y si en cambio supera dicha cantidad de hijos, corresponde la mitad de la porción hereditaria ab intestato. d. En cuanto al ejercicio de la "querella de inoficiosidad", dispone que el legitimario sólo puede interponerla cuando no es instituido heredero o cuando no es legítimamente desheredado. e. También establece que siempre el legitimario debe recibir algo en calidad de heredero, no basta que reciba todo o parte de su porción de la legítima en concepto de legados, fideicomisos u otras donaciones. f. En cuanto al efecto de la "querella", determina que la misma hace caer el testamento en cuanto a la institución de heredero, y no en su totalidad, quedando en vigor todas las demás disposiciones testamentarias, v.gr., tutelas, manumisiones, legados, fideicomisos, etc.

XVIII. CONSIDERACIONES SOBRE LA EVOLUCIÓN DE "LA LEGÍTIMA"

Tratando el tema de "la legítima", se encuentra en el derecho romano, como a lo largo de su extenso desarrollo, el humanismo y sentido común que tanto caracteriza a sus juristas. La realidad práctica cotidiana les indica a estos últimos que la amplia e ilimitada libertad de disposición testamentaria para omitir o desheredar a sus herederos más cercanos origina múltiples injusticias, con lo cual idean un sistema fundado en la "ficción legal" que les permite atacar el testamento, haciéndolo caer por injusto, provocando la apertura de la sucesión ab intestato.

XIX. EL FIDEICOMISO⁽⁷⁸⁾

Se entiende por fideicomiso la disposición de última voluntad efectuada por el causante a modo de simple ruego a una persona de su confianza para que se ocupe del destino de los bienes de su herencia, o de llevar a cabo cualquier otro acto que expresamente le solicite.

El fideicomiso es conocido e implementado en Roma desde muy antiguo, siendo primero contemplado por la costumbre, y luego, debido a su auge, regulado por la ley. Se encuentra desprovisto de formalidades e incluso puede no encontrarse inserto en el testamento, sólo descansa en la confianza de que el causante deposita en la persona elegida, que puede ser o no beneficiaria de la herencia, v.gr., heredero, legatario, etc.

La ausencia de formalidades origina que el fideicomiso pueda efectuarse oralmente, por testamento o codicilo. Basta la utilización de términos simples: "pido" (peto); "ruego" (rogo); "quiero" (volo); "encomiendo a la fe" (fideicommito), etc., efectuados en cualquier idioma.

El término fideicomiso proviene de fidei commissum ("lealtad comisionada"), puesto que se basa fundamentalmente en la honradez y lealtad de la persona llamada a cumplir con la voluntad del causante (fidei). Los romanos utilizan el fideicomiso por practicidad puesto que, al carecer de formalidades y estar fundado en la confianza que se deposita en la persona elegida, pueden disponer de la herencia, o parte de ella, respecto de personas que se encuentran excluidas de acceder a ella por carecer de aptitud legal, v.gr., extranjeros, solteros excluidos por las leyes caducarias de Augusto, etc.⁽⁷⁹⁾

Si bien en un principio el fideicomiso no presenta exigibilidad jurídica ante el incumplimiento de la persona encomendada a llevarlo a cabo, luego cambia esta postura, y durante los gobiernos de Augusto y Claudio se autoriza a su beneficiario a exigir su cumplimiento por vía del "procedimiento extraordinario ante los cónsules" en Roma y ante los "gobernadores" en las provincias. Luego se crea una magistratura con jurisdicción específica en la materia, los "pretore fideicomisarios" (praetores fideicommissarii), lo que demuestra lo arraigado del fideicomiso en la práctica⁽⁸⁰⁾.

Dada la falta de exigencia de formalidades para su otorgamiento, también carece de ellas su revocatoria, limitándose tan sólo a la expresión de la voluntad del testador en tal sentido⁽⁸¹⁾.

El fideicomiso, según su contenido, puede ser a título particular o universal. En el primer caso, recae sobre objetos perfectamente determinados, y en el segundo, sobre la totalidad de la herencia o una parte de ella⁽⁸²⁾. La jurisprudencia romana pronto advierte la similitud que existe entre el fideicomiso a título particular y el legado, decidiendo que la normativa implementada para este último también se debe aplicar al primero.

XX. EL CODICILO⁽⁸³⁾

Es la expresión de la última voluntad del causante, redactada sin ninguna formalidad, que contiene una o varias disposiciones mortis causa. "Codicilo" (codicillo) proviene del diminutivo de código (codex), y significa "pequeño rollo o cuaderno".

El codicilo aparece en Roma casi simultáneamente con el fideicomiso, puesto que los pedidos o ruegos contenidos en este último por lo general se efectúan por escrito, v.gr., una carta. El primero en otorgarle valor jurídico es Augusto, ante una solicitud del cónsul Lucio Léntulo, quien, enfermo de gravedad y lejos de Roma (en África), le solicita que acceda a confirmar el codicilo que redacta, y luego confirma por testamento. Augusto, con el fundamento jurídico del jurista Trebacio, accede a este pedido y le otorga valor jurídico al acto⁽⁸⁴⁾. De modo similar al fideicomiso, el otorgamiento del codicilo no está sujeto a ninguna formalidad, exigiéndose únicamente que el testador y el beneficiario gocen de aptitud legal para dar y recibir testamento (ius testamenti factio). Debe aclararse que por medio del codicilo no puede nombrarse heredero ni proceder a la desheredación⁽⁸⁵⁾. Más tarde, si bien la falta de formalidades implica una considerable mejora

positiva en las disposiciones testamentarias, ello apareja inseguridad e incertidumbre. Por ello Constantino impone como recaudo legal que los codicilos ab intestato lleven necesariamente la firma de cinco a siete testigos, según cada caso. Luego Teodosio II extiende este requisito a todo tipo de codicilos, agregando que los testigos tienen que encontrarse presentes en el acto. Justiniano, por su parte, confirma todas estas exigencias⁽⁸⁶⁾.

Existen dos tipos de codicilos: el testamentario y el ab intestato. El primero se denomina así por cuanto se encuentra contenido en el testamento, considerándose un accesorio de éste. El segundo es aquel que se redacta sin la existencia de un testamento⁽⁸⁷⁾.

FRANJA
MORADA

Capítulo XVI - La Sucesión Legítima o Ab Intestato

CAPÍTULO XVI - LA SUCESIÓN LEGÍTIMA O AB INTESTATO⁽¹⁾

Puede definirse como aquella que tiene lugar cuando la ley suple la voluntad del causante respecto del llamado de sus herederos. La sucesión legítima tiene lugar cuando: a) el causante no ha dejado testamento al morir; b) el testamento otorgado no tiene validez; c) el instituido en el testamento no llega a convertirse en heredero.

Por su parte, las fuentes romanas definen a la sucesión ab intestato del siguiente modo: "Muere intestado aquel que no ha hecho absolutamente ningún testamento, o no lo hizo en derecho, o cuyo testamento se ha roto o hecho írrito, o por virtud del cual nadie ha sido heredero"⁽²⁾.

De ello se infiere que en Roma el llamado a apertura de la sucesión ab intestato tiene lugar cuando no media testamento. La existencia de este último condiciona la herencia, por cuanto es la última voluntad del difunto la que prevalece, la cual necesariamente debe respetarse mientras guarde los recaudos legales. Es decir que la sucesión ab intestato presenta carácter supletorio o de subordinación respecto de la existencia de testamento válido. Una vez que se comprueba que no existe testamento, o que éste es declarado inválido, o que la persona designada como heredero lo repudia, necesariamente se debe considerar la procedencia de la sucesión ab intestato, llamando a aquellas personas que la ley considera que deben ser los herederos del difunto.

En Roma, la sucesión legítima se funda sobre la base de los vínculos de parentesco que unen a los miembros del grupo familiar. De acuerdo con ellos, se establece qué personas deben ser reputadas como herederas del causante. Debe recordarse que el concepto jurídico del parentesco en la jurisprudencia romana sufre profundos cambios según el paso del tiempo, virando del vínculo civil (agnaticio) al vínculo de sangre (cognaticio). El vínculo jurídico que impera en Roma es el primero, luego lentamente se lo deja de lado gracias al derecho honorario, y se lo reemplaza por el vínculo de sangre, que es el que rige en nuestros días⁽³⁾.

I. LA SUCESIÓN AB INTESTATO Y LA LEY DE LAS XII TABLAS. LOS ÓRDENES SUCESORIOS

La ley de las XII Tablas fundamenta, como ya se dijo, el sistema sucesorio en el parentesco civil (agnaticio). La preponderancia de este vínculo se funda en un pasaje de ésta, que expresamente reza: "Si muere intestado sin herederos suyos, tome la familia el agnado más próximo. Si no hubiese agnados, sea heredero el gentil"⁽⁴⁾.

De acuerdo con ella, el primitivo derecho romano presenta el siguiente orden sucesorio ante la falta de testamento válido: 1º) Los "herederos suyos" (heredes sui); 2a.) El "agnado más próximo" (agnatus proximus); 3º) Los "gentiles".

1. El primer orden sucesorio dispuesto por la "ley de las XII Tablas". Los "herederos suyos" (heredes sui). División de la herencia

Son considerados "herederos suyos" los agnados que se encuentran bajo la potestad inmediata del causante al momento de su muerte. Enseña Gayo que son "herederos suyos y necesarios": 1º) El hijo. 2º) El hijo, la hija, el nieto y la nieta por vía masculina. En este caso, no es tan sólo suficiente que éstos se encuentren bajo la potestad del abuelo en la época de su fallecimiento, sino que es indispensable que el padre biológico deje de ser "heredero suyo" en vida del abuelo; sólo entonces el nieto o la nieta toman la sucesión en lugar del padre. 3º) Los demás descendientes, con tal de que se encuentren bajo la potestad del difunto al momento de su muerte. Éste es el caso de la mujer casada cum manu con el causante y los hijos póstumos de este último.

Los beneficiarios reciben la herencia en partes iguales (per capita), cualquiera sea su grado. En el supuesto de que cualquiera de los beneficiarios haya muerto con anterioridad al causante, la transmisión de la sucesión en su caso se efectúa por estirpe (representación). Todos los descendientes del "heredero suyo" prefallecido reciben la porción hereditaria de aquél y la dividen en partes iguales⁽⁵⁾.

2. El segundo orden sucesorio de la ley de las XII Tabas. El "agnado más próximo" (agnatus proximus). División de la herencia

Esta clase de herederos ingresan a la línea sucesoria ante la falta de "herederos suyos". Se considera "agnado más próximo" según las fuentes: a) la madre del difunto; b) los hermanos y hermanas; c) los sobrinos hijos de un hermano; d) los primos hijos de hermanos varones⁽⁶⁾.

La división de la herencia dentro de esta línea hereditaria se efectúa también en partes iguales (per capita), excluyendo el más próximo al de grado más remoto.

Debe destacarse que en este orden sucesorio no se admite la "sucesión por grados" (successio graduum), implicando que si el "agnado más próximo" renuncia o fallece antes de haber aceptado la herencia, ésta no se transmite a los del grado siguiente inferior, quedando entonces vacante⁽⁷⁾.

3. El tercer orden sucesorio de la ley de las XII Tabas. Los "gentiles". División de la herencia

Por último, llama a heredar a los "gentiles" a falta de "herederos suyos" y "agnados más próximos". Los "gentiles" son aquellos que se encuentran vinculados al causante por lazos de "gentilidad", es decir que pertenecen a la misma gens. Los "gentiles" concurren todos a heredar al difunto en igualdad de condiciones entre sí.

Parece ser que en tiempos de Gayo, principal mentor de la ley decenviral, la gentilidad prácticamente cae en desuso, siendo incluso este mismo autor quien así lo señala en su obra⁽⁸⁾.

II. LOS EXCLUIDOS POR LA LEY DE LAS XII TABLAS. SOLUCIÓN

Es menester dejar en claro que el orden sucesorio que emana de la ley de las XII Tabas deja de lado a otros parientes del difunto que no están llamados a sucederlo, quedando de este modo excluidos de la herencia: a) los hijos emancipados; b) los nietos por vía de la mujer; c) la mujer agnada que no tiene lazo consanguíneo con el causante; d) la madre y el hijo entre sí⁽⁹⁾.

Sin perjuicio de lo precedentemente expuesto, este sistema antiguo cumple perfectamente las necesidades fundamentales planteadas por el derecho sucesorio de la primitiva sociedad romana. Si bien la ley decenviral es rígida, concordante con el derecho quiritorio (iurus quirites) que legisla los derechos de los ciudadanos romanos, presenta imperfecciones e injusticias, apartando de la línea sucesoria del causante a los parientes por línea femenina y a aquellos vinculados por lazos consanguíneos, otorgándole primacía al vínculo agnaticio. Esto motiva que lentamente cambien las rígidas concepciones, dando paso a la inserción en este orden sucesorio a los parientes consanguíneos desplazados, hasta que finalmente el nuevo sistema hereditario reemplaza al ordenado por la ley de las XII Tabas.

Corresponde al pretor, en primer término, verdadero creador y modificador del derecho civil romano, el papel preponderante en este cambio, continuado más tarde por los emperadores

Antoninos (es el caso de los senadoconsultos Tertuliano y Orficiano), la "Constitución Valentiniana" y finalmente cristalizada por Justiniano a través de sus célebres Novelas 118 y 127⁽¹⁰⁾.

III. LA SUCESIÓN LEGÍTIMA (AB INTESTATO) EN EL DERECHO HONORARIO O PRETORIANO. LA BONORUM POSSESSIO. SUS CLASES

Se dijo oportunamente, cuando mencioné las generalidades y características del sistema sucesorio romano, que la sucesión del pretor, también llamada bonorum possessio, consiste en el derecho que tiene el heredero designado de perseguir y retener el patrimonio o la cosa que fuere del causante. Sus distintas clases son las siguientes:

1. Bonorum possessio cum re. Es la sucesión concedida por el pretor a quien considera que tiene derecho para ello. El heredero nombrado en estas condiciones no puede ser apartado o desposeído de la sucesión, ni siquiera por herederos que invoquen el orden sucesorio derivado del ius civile (ley de las XII Tablas).

2. Bonorum possessio sine re. Esta sucesión, en cambio, es otorgada por el pretor a título provisorio, lo que significa que el beneficiario puede ser apartado o desposeído por los herederos que invocan el ius civile cuando ejercitan su derecho a la herencia.

3. Bonorum possessio contra tabulas. Esta sucesión se otorga a los "herederos suyos" del causante cuando en el testamento se los deja de lado o se los deshereda sin justa causa. Los beneficiarios son los siguientes: 1º) Los descendientes legítimos nacidos o póstumos, aunque estén cautivos, si regresan a la ciudad o cuando han sido condenados a pena capital si se los indulta y a los adoptivos no emancipados. 2º) Los hijos legítimos y sus descendientes que han salido de la potestas del pater o nunca han estado bajo ella. 3º) El nieto que el abuelo ha dado en adopción a su padre emancipado, o éste al abuelo. 4º) El descendiente que el difunto ha dado en adopción a un extraño cuando el padre adoptivo lo emancipa antes de morir el ascendiente natural. 5º) El descendiente cuyo ascendiente se da en adrogación sin llevarle a la nueva familia.

La bonorum possessio contra tabulas no busca anular el testamento atacado por defectos, sino que los subsana, siendo válidas todas las disposiciones del acto vinculadas con la anomalía, que provoca la intervención del pretor.

4. Bonorum possessio secundum tabulas. La aplica el pretor en los siguientes casos: a) cuando los descendientes no han reclamado la bonorum possessio contra tabulas; b) cuando los herederos no pueden solicitarla por haber perdido el derecho para hacerlo; c) cuando ha fenecido el plazo indicado para ello.

Los requisitos de admisibilidad de la bonorum possessio secundum tabulas son los siguientes: 1) Los instituidos herederos en un testamento solemne. 2) Los instituidos herederos verbalmente o por escrito, sin las formalidades de la mancipatio o de la nuncupatio, siempre que intervengan siete testigos en el acto. 3) Los instituidos cuando el póstumo que ha sido preterido muere antes que el testador. 4) Los póstumos ajenos instituidos herederos que, según el derecho antiguo, no pueden instituirse válidamente por considerarlo, personas inciertas.

5. Bonorum possessio unde liberi. Es otorgada por el pretor en los siguientes casos: 1) Los herederos suyos (heredes sui), incluidos los hijos adoptivos, siempre que no sean emancipados. Si bien la herencia les corresponde por el derecho civil, el pretor los autoriza a hacer respetar este derecho mediante el interdicto quorum bonorum. 2) Los descendientes naturales sui iuris que serían herederos suyos (heredes sui) de haber estado bajo la potestad del difunto, siempre que al fallecer el causante no formen parte de una familia adoptiva.

El pretor en la bonorum possessio unde liberi corrige el derecho civil (ius civile) que los excluye de la sucesión.

6. Bonorum possessio unde legitimi. Respeta el orden sucesorio de la ley de las XII Tablas u otra ley; por eso el pretor le otorga la sucesión ab intestato ordinaria en este caso, respetando el parentesco de la agnación a los siguientes herederos: a) descendientes naturales sui iuris, agnados y gentiles; b) al patrono con respecto de la herencia de sus libertos y a sus descendientes, a la madre y a sus hijos (esto último agregado posteriormente por los senadoconsultos Tertuliano y Orficiano).

7. Bonorum possessio unde cognati. Este tipo de sucesión es otorgada por el pretor teniendo en cuenta el vínculo de sangre, llamando a todos los parientes naturales, ya sea por línea masculina o femenina, dentro de cierto grado, estén o no en la familia. Los llamados a la sucesión entonces son la madre y los hijos ilegítimos mutuamente; los hermanos naturales y adoptivos recíprocamente, mientras permanezcan en la misma familia.

8. Bonorum possessio unde vir et uxor. Es un tipo de sucesión otorgada por el pretor en favor del cónyuge sobreviviente cuando el difunto no deja cognados y se trata de un matrimonio legítimo (*iustae nuptiae*), sin que medie divorcio antes de la muerte.

9. Bonorum possessio de furiosi. Es la sucesión peticionada al pretor por un curador en nombre de su pupilo demente (*furiosi*), con la salvedad de que, si recupera la razón, puede aceptar o rechazar lo realizado por su curador, y si fallece sin recobrar el sano juicio, se estima como no llamado a la sucesión.

10. Bonorum possessio tamquam ex familia. Es la sucesión otorgada a favor de los agnados del liberto que no dejan herederos suyos (*heredes sui*), dejando de lado al patrono y sus herederos.

11. Bonorum possessio unde cognati manumissoris. Sucesión concedida en favor de los herederos cognados más próximos del manumisor.

12. Bonorum possessio unde decem personae. Sucesión dispuesta por el pretor en favor de los diez cognados siguientes: hijo, hija, nieto, nieta, padre, madre, abuelo, abuela, hermano y hermana del emancipado.

13. Bonorum possessio unde patronus, patrona liberique et parenti patroni patronaeque. Es la sucesión conferida al manumisor y a sus herederos, con preferencia a los cognados colaterales del liberto. Se otorga también al patrono y patrona cuando no han pedido otro tipo de sucesión, v.gr., *bonorum possessio tamquam ex familia*.

FRANJA

IV. LA SUCESIÓN AB INTESTATO EN EL DERECHO IMPERIAL. EVOLUCIÓN

En este período se continúa la tendencia iniciada por los pretores en cuanto a otorgar preponderancia jurídica a la familia de sangre sobre la agnaticia. Esto es positivo, porque dispone la admisión de parientes excluidos en el orden sucesorio⁽¹¹⁾. La evolución es la siguiente.

1. Senadoconsulto Tertuliano (*senatusconsultum Tertullianum*)

Esta disposición se la conoce también con la denominación "legislación de los Emperadores Antoninos" y es dictada durante el gobierno de Adriano. Establece que la madre es llamada en primer término a la herencia de sus hijos e hijas (legitimados o naturales), siempre que tenga el número legal de descendientes como para gozar del *ius liberorum* (tres hijos la ingenua y cuatro la manumitida)⁽¹²⁾. El senadoconsulto tiene origen en una solución aislada adoptada con anterioridad por Claudio y fundada en razones humanitarias como consuelo a una madre que tiene la desgracia de haber perdido a su hijo, permitiéndole acceder a su herencia. Se lo denomina "senadoconsulto Tertuliano" por haberlo dirigido Adriano a Ovidio Tértulo, estableciendo en él que la madre tiene preferencia con respecto a los demás parientes, con excepción de los hijos del causante, el padre natural o los hermanos consanguíneos, que la preceden en el llamado sucesorio. Para el supuesto de que junto con la madre concurren hermanas consanguíneas del causante, éstas no la excluyen, y la herencia se divide en partes iguales.

2. Senadoconsulto Orficiano (senatusconsultum Orphitianum)

Dictado en tiempos de Marco Aurelio y Cómodo, recibe su nombre del cónsul Orfito, electo en dicho período. Dispone que los hijos legítimos o naturales deben ser llamados en primer término en la sucesión de la madre, excluyendo a cualquier otro pariente civil o consanguíneo.

3. Constitución Valentiniana

Es dictada en el año 386, bajo el gobierno de los emperadores Valentiniano II, Teodosio I y Arcadio. Admite la concurrencia de los nietos nacidos de una hija premuerta del causante junto con los herederos suyos (heredes sui) y los agnados de éste, pero con la limitación de las dos terceras partes de lo que a su madre le correspondería si sobreviviera a su padre (el causante). En otro orden de cosas, también dispone que los descendientes de cualquier sexo tienen derecho a acceder a la sucesión de los ascendientes maternos en calidad de liberi. Este derecho antes sólo se les reconoce a los descendientes por vía masculina, lo que significa que a partir de esta constitución los hijos y nietos, que sólo pueden heredar al abuelo materno en tercer orden por su calidad de cognados, quedan colocados en un orden preferente.

4. Constitución Anastasiana

Dictada por el emperador Anastasio, establece que los hermanos y hermanas emancipados son llamados a la herencia de un hermano fallecido en concurrencia con los agnados del mismo grado y con preferencia a los de grado más lejano, con la salvedad de que perciben la mitad de la parte hereditaria si concurren con hermanos no emancipados.

V. LA SUCESIÓN AB INTESTATO EN EL DERECHO JUSTINIANO. LAS NOVELAS 118 Y 127

Justiniano encara profundas reformas en el orden sucesorio ab intestato, que culminan con las disposiciones contenidas en las Novelas 118 y 127. El sistema justiniano tiene la finalidad de ampliar el espectro de llamado a la sucesión ab intestato, mejorando los derechos de aquellos parientes con vocación hereditaria reconocida, pero que tienen restricciones. De este modo comienza una política de modificación y complementación de la legislación vigente sobre la materia. El esfuerzo legislativo llevado a cabo por Justiniano es encomiable, ya que adopta diversas disposiciones de importancia futura, puesto que el derecho sucesorio hasta dicho momento está constituido por un plexo legal complejo, disperso y hasta a veces contradictorio, que lo induce a unificar el tema⁽¹³⁾. De este modo, puedo decir que la actividad justiniana se encuentra destinada a lograr las siguientes premisas jurídicas: a) El vínculo de sangre otorga plena calidad de heredero ab intestato, desplazando al agnaticio. b) El parentesco de sangre se divide en tres clases: descendiente, ascendiente y colateral. c) Impone el principio de exclusión hereditaria entre los distintos órdenes de beneficiarios, de tal modo que, consagrado uno de ellos, los siguientes quedan eliminados de la herencia, así el llamado derecho de preferencia es el siguiente: primero los descendientes, luego los ascendientes y por último los colaterales. d) Dispone que dentro de cada uno de los órdenes es preferido aquel que tiene un grado de parentesco más próximo con el causante, v.gr., los padres desplazan a los abuelos y los hijos a los nietos, etc. e) Legisla el derecho de representación hereditaria, que implica que los descendientes de un grado posterior se colocan en el grado que ocupa su ascendiente premuerto en la sucesión del causante, heredando en su lugar como si éste aún estuviera vivo. f) La división de la herencia se realiza en principio por cabeza, salvo en la representación por estirpe.

VI. EL SISTEMA DE LAS NOVELAS 118 Y 127

La Novela 118 (año 543) es la base medular del nuevo régimen sucesorio dispuesto por Justiniano, luego completada por la Novela 127 (año 548)⁽¹⁴⁾. El nuevo sistema dispone, en rigor de verdad, el agregado de un nuevo orden sucesorio, siendo entonces éste el siguiente:

1º) Los descendientes. Son los llamados en primer término y excluyen a todos los demás herederos, sin distinción de origen, sexo o grado, ya sean sui iuris, aliena iuris, naturales o adoptivos. La partición de la herencia se realiza por partes iguales, y los hijos tienen derecho de representación de sus padres fallecidos.

2º) Los ascendientes, hermanos, hermanas carnales y sus hijos. Heredan a falta de descendientes del causante, excluyendo a los restantes herederos. Este orden sucesorio presenta distintas particularidades, a saber: a) Existencia sólo de ascendientes. El más próximo al difunto excluye al más lejano. Si son varios del mismo grado, la partición se lleva a cabo por cabeza. Si se presenta la sucesión de ascendientes del mismo grado, pero por líneas diversas (paterna y materna), la partición se realiza por mitades a cada línea y dentro de ellas por cabeza. b) Existencia sólo de hermanos y hermanas carnales o sus hijos. En este caso concurren todos, y la partición se efectúa por ramas entre los hermanos y hermanas sobrevivientes y los hijos de los que han fallecido. Para el caso de que sólo existan hijos de hermanos o hermanas carnales ya fallecidos, la partición se lleva a cabo por troncos o ramas. c) Existencia de ambas clases de parientes. Se ordena que para el supuesto únicamente de existencia de padre, madre, hermanos y hermanas carnales del difunto, la partición se realiza entre todos, por cabeza. Para el caso de concurrencia de hermanos y hermanas carnales con otros ascendientes más lejanos, v.gr., abuelos, la partición también se realiza por cabeza. También se considera el derecho de representación.

3) Los hermanos y hermanas de padre o madre y sus hijos. Acceden en defecto de los otros dos órdenes sucesorios indicados. Componen este llamado hereditario los hermanos y hermanas, consanguíneos y uterinos, de madre y los hijos de los prefallecidos. La partición de la herencia se realiza por ramas, excluyendo a los colaterales.

4) Los restantes parientes colaterales. Constituyen el último orden sucesorio que permite acceder a la herencia en defecto de todos los parientes anteriores. El más próximo de estos colaterales excluye a los demás, disponiendo que entre todos los parientes de igual grado la partición se realiza por cabeza.

VII. LA SITUACIÓN DEL CÓNYUGE SUPÉRSTITE

Justiniano soluciona la problemática del cónyuge supérstite, que no se encuentra contemplado en el sistema de las Novelas, concediéndole la bonorum possessio under vir et uxor, con la condición de que no estén divorciados⁽¹⁵⁾.

VIII. LA ADQUISICIÓN DE LA HERENCIA⁽¹⁶⁾

La adquisición de la herencia en Roma varía según la calidad de heredero. De dicho modo, si se trata de herederos suyos o necesarios (heredes sui), se produce de pleno derecho, mientras que si el heredero es voluntario, el acto de aceptación se denomina "adición".

IX. LA ADQUISICIÓN FORZOSA DE LA HERENCIA. LOS HEREDEROS SUYOS Y NECESARIOS (HEREDES SUI ET NECESSARI)

Son adquirentes forzosos de la herencia los "herederos suyos" (heredes sui) y los "herederos necesarios" (heredes necessarii), por ejemplo, en el primer caso, los hijos varones, y en el segundo, un esclavo manumitido e instituido heredero.

Esta clase de herederos adquiere la herencia de pleno derecho (ipso iure), lo que significa que la recibe sin su consentimiento o conocimiento, y aun contra su voluntad. Por esa razón se la denomina "adquisición forzosa". Los "herederos suyos o necesarios" adquieren la herencia en el mismo instante del fallecimiento del causante, siendo considerados como continuadores de la personalidad jurídica del difunto. Consecuencia directa de ello es la confusión que se produce entre los patrimonios del causante y del heredero. Por ello, este último tiene que afrontar las deudas de la herencia, no sólo con los bienes que la componen, sino también con los propios. Esto acarrea graves inconvenientes económicos y jurídicos a aquellos herederos que reciben una herencia cargada en exceso de deudas, a la cual, por disposición legal, no pueden renunciar.

El derecho honorario intenta paliar esta injusta situación concediendo a los "herederos forzosos" los beneficios de "abstención" (ius abstinendi) y de "separación de patrimonios" (ius separationis). El primero consiste en la autorización otorgada al heredero de no acceder a la herencia, evitando la confusión de patrimonios. El segundo, por su parte, se le concede a los acreedores contra los herederos insolventes, a fin de evitarles el acceso a la herencia⁽¹⁷⁾.

X. LA ADQUISICIÓN VOLUNTARIA DE LA HERENCIA

Es la adquisición de la herencia a cargo de los herederos llamados voluntarios (heredes voluntari). Esta categoría se encuentra compuesta por todos aquellos herederos que no integran la categoría de "forzosos". Los "herederos voluntarios" no reciben la herencia de manera compulsiva, sino que deben aceptarla. El acto voluntario de aceptación se denomina técnicamente "adición" (aditio), y se diferencia según ella provenga del derecho civil (hereditas) o del derecho pretoriano (bonorum possessio).

La primera se lleva a cabo mediante la manifestación de la voluntad del heredero de manera formal y solemne ante testigos, ya sea expresamente (cretio) o tácita (pro herede gestio), aunque esta última es menos formal que la anterior⁽¹⁸⁾. La segunda es otorgada por el pretor ante el requerimiento del heredero, y es menos solemne y formalista que la anterior⁽¹⁹⁾.

Para producirse la adición del heredero (aditio), deben cumplirse los siguientes requisitos: aptitud legal para heredar (ius testamenti factio); la herencia debe otorgarse en su favor; debe haber certeza de la muerte del causante y debe conocer la causa por la cual le corresponde heredar⁽²⁰⁾.

También resulta necesario destacar que en el caso de la herencia (hereditas) el heredero goza de un plazo de cien días para decidir sobre la conveniencia de aceptarla o no⁽²¹⁾.

Y en el caso de la bonorum possessio, los descendientes y ascendientes del difunto tienen un año para solicitarla y los restantes herederos el plazo de cien días⁽²²⁾.

También el derecho romano prevé otros plazos respecto de la adición de la herencia, que incluso varían con el paso del tiempo. Así, el pretor otorga un plazo de diez días al heredero para que analice con cierta tranquilidad respecto de la conveniencia de aceptar la herencia y, si no se manifiesta al respecto, se considera legalmente que renuncia a ella. Más tarde Justiniano eleva el plazo a un año cuando el heredero es quien peticiona ante el Príncipe, y nueve meses si lo hace ante el Magistrado, pero con la particularidad de que si no se manifiesta al respecto, se presume que acepta la herencia⁽²³⁾.

XI. LOS EFECTOS DE LA ADQUISICIÓN DE LA HERENCIA

Una vez adquirida la herencia por el heredero, éste reemplaza en un todo al causante, colocándose en su misma posición jurídica y patrimonial, considerándose que no media interrupción alguna desde el momento de producirse el deceso del difunto y el momento de la adquisición de la herencia.

En cuanto a los derechos reales, el heredero sucede al causante, salvo respecto de aquellos que se extinguen con la muerte de su titular, v.gr., servidumbres personales. Respecto de los derechos creditorios, también el heredero sucede al difunto en éstos como acreedor o deudor, con excepción de los que emanan de relaciones estrictamente personales, v.gr., locación de servicios, mandato, etc.

La adquisición de la herencia produce la extinción de los derechos reales y obligacionales entre el causante y el heredero por confusión. La fusión de ambos patrimonios produce la responsabilidad ilimitada del heredero por las deudas de la sucesión, lo que apareja un grave perjuicio cuando éstas superan al activo, e incluso el damnificado puede ser el acreedor de la herencia cuando es el deudor quien tiene su patrimonio asfixiado por las deudas que luego se transportan sobre los bienes del difunto. Si bien se adoptan algunas medidas, como ya se dijera ut supra, es el pretor quien otorga a los acreedores de la sucesión el derecho de pedir la separación de los bienes del difunto de los bienes propios del heredero (bonorum separatio)⁽²⁴⁾. Esta medida pretoriana luego se extiende a los legatarios y fideicomisarios designados por el causante.

La "separación de patrimonios" tiene por efecto principal garantizar el pago de las deudas de la herencia con sus bienes. Por tal razón, sólo puede ser invocada por los acreedores sucesorios, y no por los propios del heredero. Una vez producida la separación de los patrimonios, resulta necesario aclarar que si el acreedor de la sucesión intenta ejecutar su crédito insatisfecho, a causa del insuficiente activo sucesorio, sobre el patrimonio del heredero, no puede hacerlo, por cuanto se considera que la "separación de patrimonios" implica su conformidad con el activo del acervo hereditario del difunto⁽²⁵⁾.

MORADA

XII. EL BENEFICIO DE INVENTARIO

El beneficio de inventario es el modo de aceptar la herencia por parte del heredero voluntario, con la obligación de efectuar un inventario detallado y estimado de los bienes del causante, según el estado en que se encuentren a su muerte⁽²⁶⁾. El inventario se efectúa en presencia de un oficial público denominado "tabulario" (tabularii), antecesor del actual notario, y de los acreedores, legatarios y fideicomisarios que deseen presenciario. A falta de estos últimos, se suple su ausencia mediante la presencia de tres testigos idóneos residentes en el lugar y que sean propietarios.

El instrumento redactado por el "tabulario" y firmado por el heredero contiene la estimación del importe de la herencia, y la declaración del heredero que actúa de buena fe. Para el caso de que éste no sepa firmar, signa una cruz y otro "tabulario" distinto al redactor del instrumento firma el documento por aquél. El inventario debe iniciarse dentro de los treinta días de tomar conocimiento el heredero de su llamado a la herencia y ha de concluirse dentro de los sesenta días posteriores, con un máximo de un año para el caso de que los bienes hereditarios se encuentren en un lugar alejado del domicilio del heredero. Una vez concluido el inventario, el heredero comienza a pagar las deudas de la sucesión según el siguiente orden: 1º) los acreedores privilegiados. 2º) Los acreedores quirografarios. 3º) Los legatarios. 4º) Los fideicomisarios.

Una vez satisfechos los créditos y mandas de la herencia, el remanente queda para el heredero. Destaco que, salvo el orden preferencial indicado, los pagos se efectúan a medida que los acreedores se presentan con el reclamo. Además, el heredero tiene la facultad de hacer valer contra los legatarios el beneficio que le concede la lex Falcidia, que le permite la intangibilidad de "la cuarta parte del acervo hereditario"⁽²⁷⁾.

XIII. LA HERENCIA YACENTE (HEREDITAS IACENS)

Se considera "herencia yacente" (hereditas iacens) al estado jurídico de aquélla cuando no existen herederos forzosos del causante durante el período de tiempo comprendido entre el llamado a adquirir la herencia y su aceptación por los herederos voluntarios⁽²⁸⁾. Es la etapa jurídica de la sucesión, conocida precisamente como "herencia yacente", en la que ésta constituye un verdadero "ente de existencia ideal" y continúa provisoriamente la personalidad jurídica del causante, hasta tanto los herederos voluntarios se presenten a manifestar su "adición". La herencia en este estado ("yacente") adquiere todas las cosas que pueden incrementar el acervo hereditario sin el concurso humano, v.gr., accesiones y frutos. Además, puede acrecentar el acervo hereditario a través de sus esclavos por los negocios jurídicos inter vivos que lleven a cabo en su nombre y mortis causa, cuando son instituidos herederos de un extraño. También como continuadora provisoria de la persona del causante, sigue con la adquisición de la usucapión iniciada por el difunto. Asimismo, la "herencia yacente" asume obligaciones, respondiendo por los delitos cometidos por sus esclavos y por los gastos realizados en beneficio de su acervo, v.gr., sufragar una gestión de negocios⁽²⁹⁾.

XIV. LA HERENCIA VACANTE (HEREDITAS VACANS)

Ello acontece cuando no existe heredero alguno llamado a recibirla, cualquiera sea su causa⁽³⁰⁾. Una vez que la herencia se declara "vacante", sus bienes pasan al fisco. Pero para evitar que éste se haga cargo de una herencia dañosa (hereditas damnosa), es decir que el pasivo supere al activo, con el lógico perjuicio que esto le ocasiona, se dispone que el fisco no hereda forzosamente sino que debe mediar su expresa aceptación. Esto significa que el fisco acepta la herencia sólo hasta el monto del activo, debiendo satisfacer los legados, fideicomisos y manumisiones. El fisco tiene un plazo de cuarenta años para reivindicar su derecho a adquirir una herencia reputada vacante. Este plazo comienza a correr a partir del momento en que no quedan dudas de la inexistencia de herederos de cualquier tipo del causante⁽³¹⁾.

I. EL ACTO JURÍDICO Y LA DOCTRINA DEL NEGOCIO JURÍDICO EN ROMA

Modernamente, resulta más común hablar de negocio jurídico en lugar de acto jurídico, pero es necesario destacar que en Roma, en un principio, los juristas prefieren emplear el término "acto jurídico". Esta última denominación, en rigor de verdad, se encuentra más acorde a la realidad del jurista romano, puesto que su función consiste en brindar soluciones ante cada caso concreto que se presenta a estudio. Basta simplemente atisbar el Digesto para comprobar la recopilación de las soluciones propuestas por los juristas clásicos. Por tal motivo, resulta más preciso hablar en el derecho romano de "acto jurídico" en lugar de "negocio", dejando a salvo que los mismos juristas romanos con posterioridad también emplean el término "negocio", formado por la partícula negativa *necy* la palabra *otium*, que significa lo contrario a ocio, es decir, lo que representa una actividad económica.

Lo cierto es que la labor jurisprudencial romana descansa en el saber de los juristas que la ejercitan cada vez que se les presenta a su análisis un caso concreto. Mucho después aparece la "teoría del negocio jurídico", conformada mediante abstracciones y conceptualizaciones modernas provenientes del mismo derecho romano.

El paso o transición del concepto romano de acto jurídico al de negocio jurídico moderno se produce, primero, mediante el trabajo de la doctrina bizantina, siguiendo por la medieval y la moderna, para luego continuar con la pandectística alemana del siglo XIX, finalizando en la doctrina civilista actual. Lo interesante de esta evolución doctrinaria radica en que siempre se trabaja sobre el sustrato inmejorable e incontrastable de reglas uniformes y coherentes creadas por los juristas romanos en sus soluciones ante el caso real que se les presenta. No se encuentran en el derecho romano clásico doctrinas, sistemas y conceptos, sino soluciones y aplicaciones de principios constantes y con sentido común. Luego, estas reglas emanadas de los innumerables casos prácticos sometidos a la labor cotidiana de los juristas romanos clásicos, son tomadas por la doctrina bizantina, medieval y moderna, y les dan forma, surgiendo, entonces, las generalizaciones que, recogidas más tarde por la pandectística alemana del siglo XIX, conducen a la labor contemporánea sobre la temática del negocio jurídico.

Es decir, en otras palabras, la teoría moderna del negocio jurídico es el resultado de la abstracción, conceptualización y sistematización evolutiva de la labor jurisprudencial del jurista romano clásico, emanada de los casos prácticos que se someten a su estudio. Así, el sustrato del negocio moderno descansa simplemente en el clásico acto jurídico romano⁽²⁾.

II. CONCEPTO DE HECHO Y ACTO JURÍDICO(3)

Efectuada la consideración necesaria respecto de la evolución del acto jurídico y su devenir en la doctrina moderna del negocio jurídico, es menester desarrollar los aspectos básicos que refieren a este último en Roma y su influencia en el derecho moderno.

El estudio de la jurisprudencia romana permite inferir que hecho es todo acontecimiento o suceso producido por la naturaleza o el hombre que forma parte del mundo de los sentidos y las percepciones.

En primer lugar, debe dejarse en claro la diferencia entre "hecho simple o natural" y "hecho jurídico". El hecho simple es el acontecimiento o suceso que emana de la naturaleza o del hombre, y

que no produce ningún tipo de consecuencias o efectos jurídicos, v.gr., la lluvia, un atardecer, pasear, escribir una carta de salutación, etc. Por el contrario, el hecho jurídico es el acontecimiento o suceso que proviene de la naturaleza o del hombre, y que produce consecuencias jurídicas, v.gr., las inundaciones, la tempestad que hunde un navío, redactar un testamento, adoptar un hijo (filius), reconocer una deuda mediante el envío de una carta, etc.

Puede decirse entonces que se considera propiamente acto jurídico a "todo aquel hecho jurídico en el cual interviene la voluntad del hombre"⁽⁴⁾.

Por supuesto que no sólo le basta lo expuesto a la jurisprudencia romana para referirse al acto jurídico, sino que necesariamente tiene que tener en cuenta su licitud, es decir, que el hecho jurídico voluntario debe enmarcarse en lo legal, debe ser lícito. En caso contrario, la ilicitud aparea un delito y ello resulta contrario al derecho.

Tras lo expuesto, puedo señalar que el derecho romano visualiza al acto jurídico como el "hecho voluntario lícito que produce consecuencias jurídicas".

III. CLASIFICACIÓN DE LOS NEGOCIOS JURÍDICOS⁽⁵⁾

El negocio jurídico ha sido pasible de distintas clasificaciones efectuadas por los juristas modernos a efectos de facilitar su mejor comprensión y estudio. Una vez más es menester dejar en claro que el jurista romano clásico no se preocupa en brindar una clasificación del negocio jurídico, puesto que su labor consiste esencialmente en dar soluciones a las controversias que se someten a su análisis. Es entonces la actividad del jurista moderno la que toma la extensa y proficua labor del primero y elabora la tan mentada clasificación de los negocios jurídicos. Realizada esta previa aclaración, se verá a continuación la clasificación de los negocios jurídicos, teniendo en cuenta para ella los distintos puntos de vista que le otorgan fundamento.

a) Por su objeto se dividen en patrimoniales y extrapatrimoniales. Los primeros son aquellos que tienen en mira la adquisición, modificación o extinción de los derechos reales y crediticios, v.gr., en el derecho quiritario tenemos la mancipatio, el nexum, el testamentum per aes et libram, etc., y más tarde, la transmisión de la propiedad, constitución de servidumbre, compraventa, testamento, etc. Los segundos giran en torno a la adquisición, modificación y extinción de los derechos relacionados con las personas y la familia, v.gr., emancipación, adopción, matrimonio, etc.

b) Desde el punto de vista del orden jurídico que le da origen, se dividen en aquellos provenientes del "derecho civil" (ius civile) y del "derecho de gentes" (ius gentium). Los primeros se originan en el derecho civil, es decir que se aplica exclusivamente a los ciudadanos romanos, v.gr., mancipatio, la in iure cesio, etc. Los originados en el ius gentium nacen del derecho común a todos los pueblos a los cuales acceden por lo general los peregrinos, v.gr., la traditio, la compraventa, etc.

c) Teniendo en cuenta su causa, es decir, el fin práctico que persiguen, se los puede distinguir en causales y abstractos. Los causales son aquellos cuyos fines surgen del mismo negocio, v.gr., la compraventa, la donación. Los otros, en cambio, son aquellos cuya causa no surge del mismo negocio, sino de modo independiente a la misma, v.gr., la stipulatio (promesa abstracta de una prestación cualquiera).

d) Según las partes que intervienen en la celebración, se dividen en unilaterales y bilaterales. En los primeros interviene una sola voluntad, v.gr., el testamento, la donación, la aceptación de una herencia, etc., mientras que en los segundos lo hacen por lo menos dos personas, v.gr., el contrato.

e) Desde el punto de vista del momento en que comienzan a generar efectos, tenemos "actos inter vivos" y mortis causa. Los primeros generan efectos en vida de aquel que los celebra, v.gr., el contrato, mientras que los segundos lo hacen después del fallecimiento de la persona que los genera, v.gr., el testamento.

f) Contemplando las formalidades tenidas en cuenta para su validez, se los puede considerar en formales y no formales. Los formales son aquellos que hacen depender de sus formas la propia validez del acto. Esencialmente, son los actos jurídicos del derecho quiritario, v.gr., la mancipatio, la stipulatio, etc. Los segundos no hacen depender de sus formas el presupuesto de su validez. Nacen producto de la evolución de la jurisprudencia romana, v.gr., el contrato.

IV. ELEMENTOS DEL NEGOCIO JURÍDICO⁽⁶⁾

De la jurisprudencia romana puede inferirse que existen en principio dos tipos de elementos del negocio jurídico: esenciales y accidentales, aunque también se puede considerar un tercer tipo, llamado naturales.

En mi opinión, debe considerarse únicamente como elementos del negocio jurídico a los dos primeros, puesto que los denominados "naturales", y adelanto mi parecer al respecto, no deben tenerse en cuenta precisamente como elemento del negocio jurídico, sino exclusivamente para la compraventa. La cuestión será analizada más adelante.

V. ELEMENTOS ESENCIALES DEL NEGOCIO JURÍDICO⁽⁷⁾

Se denominan elementos esenciales del negocio jurídico (*essentialia negotii*) a aquellos que hacen a su misma existencia, de modo tal que si falta uno de éstos, no existe el negocio jurídico en sí. Ellos son el sujeto, el objeto y la causa.

1. El sujeto como elemento esencial. La voluntad

1.1. La voluntad

El sujeto es uno de los elementos esenciales del negocio jurídico debido a que el derecho íntegro gira en torno suyo. Pero, en rigor de verdad, lo que la jurisprudencia romana tiene más en cuenta es la manifestación de su voluntad.

A mi entender, no solamente habrá de tenerse en cuenta la voluntad como elemento esencial del negocio jurídico, sino al sujeto de quien emana, sin olvidar la preponderancia que tiene para el negocio en sí su manifestación⁽⁸⁾. En principio, cuando se alude al "sujeto de derecho", debe tenerse en cuenta que la jurisprudencia romana se refiere, según el caso, tanto al sujeto de "existencia visible" (el hombre) como al de "existencia ideal" (las asociaciones)⁽⁹⁾ (conservando la terminología utilizada por nuestro codificador Vélez Sarsfield).

Además, el sujeto debe ser capaz, tanto de derecho⁽¹⁰⁾ como de hecho⁽¹¹⁾, y en este último caso, si se encuentra ella afectada, se suple la incapacidad mediante los institutos de protección creados a tales efectos, es decir, la tutela y la curatela⁽¹²⁾.

En cuanto a la voluntad, se requiere precisamente su manifestación. Ello debe quedar en claro, puesto que para el mundo del derecho es fundamental que ella se manifieste en cualquiera de sus formas, expresa, tácita, comportamiento inequívoco, silencio asertivo, etc. Es decir, cualquier modo que exprese el "querer volitivo" del sujeto en la celebración del negocio. Lo que lleva a interpretar que una voluntad no expresada no existe⁽¹³⁾, simplemente es un deseo que nace y muere dentro del sujeto, salvo los supuestos que indiquen que esa falta de manifestación de la voluntad significa para el derecho precisamente su exteriorización.

1.2. Formas de manifestación de la voluntad. El silencio⁽¹⁴⁾

El modo expreso de la manifestación de la voluntad es aquel llevado a cabo por cualquier medio que permita exteriorizar el "querer volitivo" del sujeto, es decir, la transmisión al mundo exterior de su pensamiento, v.gr., la palabra oral o escrita, un gesto con la mano o cabeza, etc.⁽¹⁵⁾. El modo tácito, por el

contrario, es aquel que surge de una actitud, conducta o comportamiento inequívocos del sujeto que guarda una relación de conformidad con el acto jurídico de que se trate.

Merece consideración aparte el silencio y su valor como modo de expresión de la voluntad. Puedo afirmar que éste, según el estudio de las fuentes, es considerado como una demostración de la voluntad, según los casos concretos que se suscitan en análisis. Por ello puedo señalar que el silencio no se considera como un modo de expresión de la voluntad, salvo que las circunstancias que acompañan al acto permitan atribuirle un significado cierto⁽¹⁶⁾ o que la propia ley le otorgue expresamente un valor de expresión⁽¹⁷⁾. Dicho de otro modo, el silencio en sí mismo no es considerado un modo de exteriorización de la voluntad, excepto que las particularidades del caso permitan darle dicho valor.

1.3. La publicidad del acto en el derecho romano⁽¹⁸⁾

Los juristas romanos saben muy bien el significado de lo que actualmente se conoce como "publicidad del acto", y esencialmente su efecto primordial, "oponibilidad a terceros". La característica fundamental que forja la grandeza del derecho romano es precisamente el espíritu práctico de sus juristas, evidenciado en brindar solución inmediata al problema concreto que se les presenta en estudio. En otras palabras, ellos deben decidir sobre la vida misma que pasa frente a sus ojos inmersa en el caso a juzgar. Comprenden perfectamente que el derecho no es otra cosa que conducta humana. Luego, como dijera, del casuismo clásico romano, los juristas posteriores toman su coherencia significativa, que se manifiesta en principios rectores en todo el derecho del futuro mundo occidental⁽¹⁹⁾.

El jurista romano de manera inmediata entiende que el derecho debe manifestarse (publicidad) para que el resto de la sociedad tome debida cuenta de ello (oponibilidad). Por tal razón, en diversas instituciones del derecho romano se encuentra la exigencia de distintos y variados requisitos formales que no hacen sólo a su validez, sino a la necesidad de darlos a conocer al resto de la sociedad, es decir, grabar en la memoria colectiva la importancia del acto llevado a cabo (publicidad), y no sólo para los propios interesados, sino para generar efectos ante los demás (oposición). Lo expuesto, a modo de ejemplo, se manifiesta en la celebración del matrimonio; el sistema obligacional antiguo (stipulatio, in iure cesio, mancipatio, nexum); la adopción y sus distintas clases ("adoptio" y "adrogatio"); y en materia sucesoria, la designación de heredero, etc.

En la actualidad, estos principios rectores emanados del derecho romano (publicidad y oponibilidad) quedan reflejados en la creación de los distintos registros, v.gr., personas, prendario, catastral, notarial, etc., que, por otra parte, han tenido su origen en la misma Roma.

Lo expuesto me permite aseverar, una vez más, que el derecho romano necesariamente ha de ser valorado, no como un derecho perimido para ser enseñado como un capítulo de "Historia del Derecho y de las Instituciones", sino, por el contrario, como derecho actual, puesto que se encuentra transfigurado en las legislaciones modernas, obteniéndose del derecho romano permanentes enseñanzas que hoy en día llamamos modernismo, ignorando posiblemente que aquél las había creado siglos antes⁽²⁰⁾.

2. La problemática de la representación⁽²¹⁾

Puede decirse que es una problemática en la jurisprudencia romana la representación, ya que lo dicho anteriormente respecto de la voluntad se refiere siempre a la manifestación directa del sujeto, sin intermediarios o representantes de ninguna especie. Esto es así, por cuanto los romanos desde antiguo no admiten ningún tipo de representación directa, sino que dan únicamente validez a la presencia del sujeto en el negocio jurídico.

La falta de admisibilidad de la representación directa se basa fundamentalmente, entre otras causas, en que los negocios jurídicos descansan fundamentalmente en la oralidad del acto, el cumplimiento de fórmulas sacramentales y en la particular concepción de la familia romana primitiva, en la cual solamente tiene validez la voluntad del pater familias, mientras los restantes miembros de la familia, v.gr., filius, esclavos, constituyen meros instrumentos de adquisición de aquél.

Estas causas inducen a sostener que únicamente aquel que participa en el negocio jurídico es el dueño de la voluntad que genera efectos (dominus negoti), no teniendo, por ende, aceptación que el

sujeto sea representado en tal crucial momento⁽²²⁾. Luego, muy lentamente, los juristas conciben la idea de que resulta práctico y necesario que el sujeto pueda ser representado, de modo directo o indirecto, en la celebración de determinados negocios jurídicos por medio de otra persona. Este cambio de concepción se adopta gracias a la movilidad intelectual y aperturista de los juristas romanos, que advierten la practicidad de la representación que favorece la agilidad de los negocios, acortando distancias y tiempos⁽²³⁾.

Es menester dejar en claro que esta evolución de muy lenta configuración se lleva a cabo únicamente mediante excepciones. Esto quiere decir que el principio general establece que no es admisible la representación directa, aunque se acepta en determinados casos el modo indirecto. Mas luego, esta idea varía y las excepciones comienzan a ser tenidas cada vez más en cuenta por los mismos juristas. Me permite arribar a esta conclusión el estudio atento y pormenorizado de las fuentes, que deja entrever que los juristas parten de una concepción, si se quiere un tanto conservadora, para luego, mediante la implementación de excepciones al principio general, paliar los puntuales requerimientos que el tráfico jurídico clama⁽²⁴⁾. No es de extrañar este procedimiento, propio de los juristas romanos, puesto que se trata de un modo atinado y particular de su evolución, producto de la madurez jurídica y que advierto en el estudio de otras instituciones, tales como, la persona por nacer (nasciturus).

En cuanto a la representación propiamente dicha, puedo señalar las siguientes excepciones que conducen a su aceptación. Así, desde muy antiguo, la utilización por parte del pater familias de la figura del "anunciador o mensajero" (nuntius), que no lo representa ni menos aun lo obliga, pero, en cambio, es portavoz de su voluntad⁽²⁵⁾. También los casos del "hijo de familia" (filius) y del esclavo que adquieren para el patrimonio del pater, aunque éste no tenga conocimiento de ello. Y si bien en un principio no le genera responsabilidad, luego la actividad del pretor se la extiende a través de las "acciones de responsabilidad" (actiones adiecticiae qualitatis)⁽²⁶⁾. En materia posesoria se admite, primero, que la misma puede ser ejercida por medio de un tercero, y más tarde, que puede ser directamente adquirida por éste⁽²⁷⁾. Similar evolución se advierte en cuanto a la adquisición del dominio, puesto que, al ser superadas las formalidades solemnes de la Mancipatio y la In iure Cessio por la traditio, el dominio es adquirido directamente por medio de representantes⁽²⁸⁾. En materia sucesoria se admite "la adquisición de la herencia por posesión" (bonorum possessio) a través de la intervención de un tercero (procurador)⁽²⁹⁾. También se encuentra la representación en los institutos de guarda de los incapaces, concretamente en las funciones del tutor y del curador⁽³⁰⁾. Finalmente, la aceptación de la representación directa se configura con el mandato y la gestión de negocios⁽³¹⁾.

3. Vicios del consentimiento⁽³²⁾

Los juristas romanos enseñan que la voluntad que emana del sujeto debe ser espontánea, y que ésta no debe encontrarse afectada por ningún tipo de causa que provoque en ella una decisión contraria. Estas causas que afectan de un modo u otro la voluntad del sujeto se denominan vicios del consentimiento.

El tratamiento del tema merece la misma consideración efectuada ut supra. Los juristas romanos clásicos no elaboran una "teoría general de los vicios del consentimiento", sino que, por el contrario, son los posclásicos quienes comienzan a elaborarla, tomando en cuenta el proficuo trabajo jurídico llevado a cabo por aquéllos en la resolución de los casos cotidianos sometidos a decisión.

Los vicios del consentimiento pueden ser de dos clases: por un lado, los "conscientes o intencionales", a saber, simulación, reserva mental, declaración iocandi gratia; por otro, los "inconscientes o no intencionales", error, dolo y violencia.

3.1. Los vicios del consentimiento conscientes o intencionales

3.1.1. La simulación. El fraude

La simulación (*negotium simulatum*) consiste en aparentar la celebración válida de un negocio jurídico cuando la realidad indica lo contrario. Es decir, se expresa la voluntad aparentando ser la cierta, cuando en realidad se oculta la verdadera. La simulación puede ser absoluta y relativa.

Es absoluta, cuando si bien se expresa la voluntad para la celebración del negocio, en rigor de verdad, no se lo quiso nunca llevar a cabo. Y es relativa cuando la celebración del negocio intenta ocultar al verdadero. O sea que tenemos dos actos: uno visible y otro oculto⁽³³⁾.

También los juristas romanos sostienen que la simulación, en cualquiera de sus formas, cuando causa un perjuicio a los acreedores, configura un fraude. Este último merece particular tratamiento por parte de los juristas, que protegen a la víctima de éste mediante la creación pretoriana de las siguientes acciones, a saber: la "acción de restitución" (*actio in integrum restitutio*) y la "acción pauliana" (*actio Pauliana*)⁽³⁴⁾.

La primera busca restituir las cosas que salen fraudulentamente del patrimonio del deudor, es decir, volverlas a su estado anterior al fraude, para permitir a los acreedores cobrar el crédito burlado⁽³⁵⁾.

La segunda se concede a los acreedores contra el deudor que lleve a cabo actos fraudulentos en su perjuicio y también contra los terceros que obtienen provecho de ello. Es creada por el pretor de nombre Paulo y se aplica principalmente en los casos de venta fraudulenta de los bienes del deudor sin satisfacer el crédito de sus acreedores. Persigue la revocación de la venta, restituyendo al patrimonio del deudor, las cosas y derechos enajenados de modo fraudulento para ponerlos a disposición de los legítimos acreedores perjudicados por el negocio. El plazo para interponer esta acción es de un año a partir de su celebración⁽³⁶⁾.

3.1.2. La reserva mental

La reserva mental (*restrictio mentales*) se configura cuando cualquiera de los sujetos que interviene en el negocio emite su voluntad, aparentando ser válida en todos los aspectos, pero en realidad se guarda para sí la verdadera intención, que es no celebrarlo.

Los juristas romanos, con excelente criterio, si bien conocen la reserva mental, luego de analizar y estudiar detenidamente la cuestión, no le otorgan validez como vicio del consentimiento, convalidando el negocio que se ataca a través de su invocación⁽³⁷⁾.

3.1.3. La declaración efectuada sin intención de seriedad (*iocandi gratia*)

Es la declaración realizada en broma o sin intención de seriedad. Ésta no genera efectos de validez para la celebración del negocio jurídico, especialmente cuando es notable su falta de seriedad⁽³⁸⁾.

Modernamente, esta teoría se encuentra relacionada con la temática de mejorar la efectiva protección del tercero ante el incremento de nuevas formas derivadas del mundo jurídico, en el cual tiene relevancia la buena fe. Parte de la consideración de que los derechos son abstracciones que se revelan mediante el ejercicio de actos materiales, que por lo general responden a una realidad jurídica subyacente; pero no siempre la existencia de actos materiales responde a un derecho subyacente y, en cambio, parecen traslucir su existencia en un todo, lo que genera la duda sobre si ha de aceptarse la prevalencia de la verdad jurídica subyacente o, por el contrario, ha de reconocerse efectos jurídicos a la apariencia creada. Justamente, la teoría de la apariencia, en consonancia con la protección del tercero de buena fe, tiende a sostener la subsistencia del derecho adquirido en razón de la apariencia habida (realidad exterior visible), siempre que se den ciertas condiciones que hacen sustancialmente a la buena fe del sujeto que ha actuado fundándose en la apariencia surgente. Entonces, teniendo en cuenta estas consideraciones, se tiene apariencia cuando un hecho antes de revelarse hace aparecer a otro fenómeno que parece real, mientras que el real es el primero y no el segundo. La apariencia consta fundamentalmente de un elemento material (acto real) y un elemento inmaterial (acto aparente). En resumen, la teoría de la apariencia intenta dar respuestas respecto de si deben prevalecer los efectos de lo aparentado por sobre lo subyacente, considerando que ha de subsistir el derecho adquirido a causa de la situación aparente con el fin de proteger al tercero de buena fe. Los principales casos contemplados por casi todas las legislaciones del mundo, incluida la de nuestro país, son los siguientes: heredero aparente, pago del acreedor aparente y mandato aparente.

Efectuado este breve pero necesario introito, me he de referir, en particular, al tema respecto del derecho romano.

En Roma no se puede hablar técnicamente de "teoría de la apariencia", por cuanto si se toma en consideración el período más importante de su apogeo en cuanto a la creación del derecho se refiere, es decir, la jurisprudencia clásica, los juristas no son en absoluto afectos a crear teorías, sino que su labor en el derecho parte exclusivamente de la realidad sobre la que trabajan, buscando soluciones ante el caso real planteado cotidianamente en el foro. Corresponde fundamentalmente el inicio de esta labor jurídica durante el período republicano al pretor y, después, en el Alto Imperio, a los grandes juristas, prestigiados con la delegación de facultades que hace el príncipe (*ius publicae respondendi*). Entonces, es recién con posterioridad al período clásico y después de la obra de Justiniano que lentamente la actividad jurídica se encamina en la reelaboración del derecho creado por los grandes juristas, dando paso a la configuración de conceptos, caracteres, efectos, etc., de las instituciones jurídicas y el contenido de las teorías. Nos encontramos, entonces, en la antesala del mundo jurídico moderno.

En suma, debe quedar en claro que en Roma durante el período de mayor esplendor creativo (el período clásico), la actividad jurídica no visualiza en su momento de esplendor a la "apariencia" como una teoría. En cambio, es menester focalizar la cuestión en cuanto a que los romanos conocen y dan valor jurídico a lo que se conoce en la actualidad como "apariencia jurídica".

Como dijera, la labor jurídica intelectual del jurista romano comienza esencialmente a través de la realidad. En consecuencia, la "apariencia", entendiendo por ella "lo que se ve como real", es tenida en cuenta en la solución de los casos jurídicos sometidos a consideración. El tema de la apariencia, en Roma, tiene relación, en mi opinión, con uno de los principios fundamentales del derecho moderno, tal cual es la publicidad del acto y su oposición a terceros. Es justo reconocer, entonces, que si los juristas romanos dan en origen preeminencia a la realidad, brindando más tarde fundamento a la moderna "teoría de la publicidad del acto", que, por otra parte, es también, de algún modo, el fundamento que emplea respecto del tema de la apariencia, en principio, la pandectística germana, que la vincula con el "principio general de la publicidad cuyo objetivo es la tutela de la fe pública", nos acercamos lentamente a la idea de que los juristas romanos conocen y dan aplicación jurídica a la apariencia en la solución de los conflictos jurídicos y también en el tráfico jurídico en general.

Partiendo de esta premisa, para el jurista romano, en los casos que se presentan a estudio, "la apariencia es lo real", lo que quiere decir que lo aparente genera efectos en favor de aquellos que creen en ello y deben ser protegidos por sobre la realidad subyacente. Es posible que sea más fácil explicar los fundamentos y necesidades de ser de la "teoría de la apariencia" en sentido moderno, que hacerlo en la vida romana, dado la dificultad de comprensión para aquellos que no conocen el tema en Roma. Incluso, posiblemente dentro de los mismos romanistas, podrá existir disenso al respecto. En mi opinión, fundada en la firme creencia doctrinaria adquirida a través del tiempo, soy un firme defensor de la idea de que todo el mundo jurídico occidental ha tenido origen en el romano y, por ende, casi todas las doctrinas y teorías modernas no son sino la consecuencia evolutiva o transformaciones temporales de los principios acunados en Roma. Por ello, no me es forzoso señalar que la "apariencia como teoría" no es conocida en Roma, por las razones expuestas *ut supra*, pero sí es conocida y aplicada la "apariencia jurídica en sí misma" en la soluciones del tráfico jurídico cotidiano.

Los casos jurídicos romanos, que puedo señalar como antecedentes que conformaron lo que hoy se denomina "teoría de la apariencia jurídica", son los siguientes:

a) El mandato aparente. El mismo se presenta, según las fuentes romanas, cuando el mandatario, sin saber que el mandante ha fallecido, lleva a cabo actos jurídicos en cumplimiento del mandato que oportunamente le otorgara. Los juristas romanos deciden al respecto que dichos actos deben ser considerados válidos y los herederos del causante (ex mandante) deben cumplirlos⁽⁴⁰⁾. Si bien el mandato como instituto jurídico es romano, no lo es desde un principio, por cuanto, debido a los caracteres personales y sacramentales de los actos, no se admite la representación en ellos, hasta que se comprende que es necesario aceptarla para agilizar notoriamente la vida jurídica y económica.

Pero más allá todavía encuentro la apariencia como tal, en la etapa previa a la aceptación del mandato, en la celebración antigua de los viejos actos jurídicos, cuando quien desea adquirir alguna cosa le solicita a otro que lo haga, y éste adquiere la cosa en derecho propio, comprometiéndose ante el tercero en forma personal. Luego, en un segundo acto y absolutamente autónomo del primero, a su vez, transfiere o cede el resultado de su primera gestión a quien en realidad le ha solicitado que lo hiciese. Esta operatoria mediante dos actos absolutamente distintos es necesaria hasta el reconocimiento de la figura del mandato. Lo cierto es que, y empleando la terminología moderna, si el verdadero titular subyacente (el que ordena) y el titular aparente (el que cumple) entran en conflicto y no llevan a cabo el segundo acto, lo que importa jurídicamente para la solución del conflicto ante un eventual reclamo del tercero es considerar la validez del acto cumplido (apariencia), generando efectos a favor de este último, sin perjuicio de la realidad subyacente entre los dos primeros⁽⁴¹⁾.

b) La manumisión de esclavos. Es otro claro ejemplo de apariencia que demuestra, incluso, el sentido humanista de los juristas romanos. Se trata de las manumisiones consideradas no solemnes, cuando se le concede la libertad al esclavo permitiéndole sentarse a la mesa del amo (per mensan), o que este último manifiesta la libertad del esclavo ante amigos (inter amicos). En estos casos, existen en las fuentes soluciones en favor de la manumisión, ante planteamientos posteriores del amo destinados a no considerar la validez del acto. La solución se funda en que si el liberto ha creído que realmente se le ha otorgado la libertad y, por ende, se comportó como hombre libre por espacio de veinte años (apariencia), es libre. La solución prima por sobre la realidad subyacente (el amo que, cualquiera sea el motivo, sostiene que no ha otorgado la libertad) en favor de los efectos creados por el tercero en buena fe (v.gr., cualquier acto del liberto)⁽⁴²⁾.

c) Los esclavos viejos y enfermos que son abandonados. Es el caso en que el amo los abandona en razón de considerar que han perdido utilidad por su enfermedad o edad y luego pretende recuperarlos cuando advierte que se han recuperado físicamente. La realidad subyacente está dada en que no se le ha otorgado la libertad y la realidad aparente se evidencia en cualquier acto realizado por los ex esclavos que genera efectos, por pequeños que fuesen, ante todo tercero involucrado, e incluso debe merecer ser contemplado, si se quiere, el derecho de los propios esclavos considerándose hombre libre⁽⁴³⁾.

d) El hombre libre que se hace pasar por esclavo. Es el caso del hombre libre que se hace pasar por esclavo (realidad aparente) para ser vendido participando de la ganancia obtenida y luego reclamar su libertad (realidad subyacente). Se decide como castigo que cae en esclavitud, configurándose un claro caso de apariencia jurídica con protección del tercero de buena fe (el que paga por la adquisición)⁽⁴⁴⁾.

e) Las ficciones. Los juristas romanos son creadores de las denominadas "ficciones jurídicas", que consisten en crear o aparentar una situación jurídica para tomar una decisión en favor de quien se ve perjudicado por una situación o la malinterpretación de un derecho. Quien trabaja mucho con las ficciones es el pretor, que utiliza fundamentalmente la equidad para contemporizar el rudoderecho quirritario con las necesidades del pueblo, es decir, a quienes el ius civile no contempla. Las ficciones consisten precisamente en aparentar una situación para proteger otra de modo jurídico. Esto quiere decir que los romanos conocen la apariencia y la utilizan como tal, incluso acertadamente, de modo voluntario y legal. En otras palabras, sobre una realidad subyacente que no es justa, se aparenta otra que es equitativa y apropiada a la necesidad de igualar el derecho del ciudadano. Son "ficciones", entre otras, la "querella de infidencia testamentaria" para proteger a los herederos forzosos dejados de lado sin motivo fundado por el testador; el procedimiento para emancipar a los hijos por los "padres de familia" valiéndose de la normativa legal dispuesta por "la ley de las XII Tablas"⁽⁴⁵⁾; la disposición de la lex Cornelia que señala que un cautivo muerto bajo el poder del enemigo debe ser considerado que ha muerto antes de su caída en cautiverio a los efectos de mantener válido su testamento⁽⁴⁶⁾.

El romanista francés Yan Thomas enseña modernamente respecto de la ficción jurídica que "la indisponibilidad de lo natural fue cuestionada sobre todo a través del procedimiento de la ficción jurídica, herramienta potente para transformar la realidad. El procedimiento consistía en transvertir

los hechos, en declararlos otros que lo que eran verdaderamente, y en sacar de esta adulteración misma y de esta suposición falsa las consecuencias de derecho que le hubieran sido adjuntadas a la verdad así asimilada, si ella hubiera existido artificialmente. Tratar como verdad lo que había sido declarado ser falso y apoyarse sobre estos datos reconocidos como irreales, tal fue el medio a través del cual los jurisconsultos antiguos ejecutaban operaciones de descalificación y de recalificación que no se hubieran alcanzado sin un tal forzamiento de los hechos"⁽⁴⁷⁾.

f) Los interdictos posesorios. Es el caso del interdicto Salviano⁽⁴⁸⁾, que autoriza al arrendador de un fundo a tomar los objetos que el colono o arrendatario ha introducido en la finca para el caso de que no pague el arrendamiento; pero si el colono o arrendatario hubiera cedido dichas cosas a terceros poseedores de buena fe, el arrendador no puede ejercer el interdicto contra ellos.

g) El pago del acreedor aparente. Se han dado casos de apariencia en este aspecto, por cuanto el derecho romano admite el pago a otra persona distinta del acreedor, puesto que se admite la cesión de obligaciones, aplicándose contrario sensu el principio que reza "lo convenido entre unos (realidad subyacente) no puede aprovechar ni perjudicar a otros (realidad aparente)".

4.1. Los vicios del consentimiento inconscientes o no intencionales⁽⁴⁹⁾

4.1.1. El error

Se entiende por error el falso conocimiento que el sujeto tiene sobre una cosa. Las fuentes lo diferencian de la ignorancia, por cuanto esta última consiste en la falta de conocimiento sobre la cosa. En rigor de verdad, las diferencias son de índole meramente doctrinaria, puesto que en la práctica los efectos del error y de la ignorancia son idénticos, no guardando importancia si media uno u otra⁽⁵⁰⁾.

Debe destacarse que la jurisprudencia romana clásica no elabora una "teoría general sobre el error", sino que trabaja en la resolución de casos concretos, recogiendo luego el fruto de su intensa labor la escuela posclásica mediante la elaboración de conceptos y clasificaciones que extrae de aquéllos.

Entonces, al estudiar el casuismo romano, puede decirse que el error presenta distintas clases, según aquello sobre lo cual recae, v.gr., sujeto, objeto, naturaleza del acto, etc.

Sin embargo, la primera enseñanza que se obtiene es que no produce el mismo efecto para el sujeto incurrir en error de hecho (error facti), que en error de derecho (error iuris), aunque en este último caso se prefiere hablar más atinadamente de ignorancia de derecho (ignorantia iuris)⁽⁵¹⁾.

El primer supuesto, error de hecho, es evaluado mediante atenuantes que permiten aseverar que éste puede ser motivo de excusabilidad para el que lo comete. En cambio, razones de seguridad jurídica permiten acuñar la idea de que el error o la ignorancia de derecho no deben ser evaluados de igual modo, ya que, por el contrario, su alegación no produce la exoneración⁽⁵²⁾. Pero, de igual modo, y dada la particular configuración de la sociedad romana, el principio general de la falta de excusación respecto del error o ignorancia del derecho admite excepciones, a saber, entre otros, las mujeres, los menores de 25 años, los militares, los que viven alejados de la ciudad, etc.⁽⁵³⁾.

Efectuada esta primera apreciación sobre el tema, resulta necesario avanzar respecto del error de hecho y sus distintas clases, y, esencialmente, en el fundamento por el cual es el único que puede ser excusable. Para que esto último se admita, sostienen los juristas romanos que el error debe ser de carácter esencial (error essentialis). Es decir, el error debe recaer sobre un elemento esencial del negocio jurídico, v.gr. el sujeto, el objeto, etc., lo cual torna al negocio in proprio, en otras palabras, nulo.

En cambio, si el error es nimio, o sea, no gravitante, puesto que afecta a un elemento no esencial del negocio, éste es considerado, en principio, válido, aunque sometido a un intenso análisis respecto de sus particulares circunstancias para evaluar su incidencia en el negocio y poder considerarlo nulo en caso de que ello resulte necesario.

Es decir que, en definitiva, el error no esencial está sujeto a la valoración de quien juzga en cada caso concreto, siendo el principio general su no consideración como factor de excusabilidad, a menos que, a modo de excepción, se entienda lo contrario ante la particularidad del caso concreto.

Las distintas posibilidades o clases de error esencial son las siguientes:

1. Error sobre el negocio (error in negotio). Es aquel que recae sobre la naturaleza misma del negocio llevado a cabo por el sujeto. Éste cree haber celebrado un tipo de negocio determinado, cuando en realidad concreta otro, v.gr., una donación en lugar de un préstamo de mutuo; una venta por una permuta; una locación por un comodato, etc.

2. Error sobre la persona (error in persona). Es aquel que recae sobre la identidad del sujeto o, dicho de otro modo, cuando la equivocación recae respecto de la identidad de la persona con la cual se quiere negociar. El error debe abarcar esencialmente las cualidades intrínsecas del sujeto a los efectos de invalidar el negocio. La mera equivocación respecto del nombre del sujeto no es un error excusable; lo es en cambio cuando la identidad afecta las condiciones particulares del sujeto que necesariamente se tienen en cuenta al celebrar el negocio, v.gr., una locación de los servicios de un profesional; la otorgación del mandato, etc.

3. Error sobre el objeto (error in corpore). Se refiere a la identidad misma de la cosa, puesto que recae sobre el objeto en sí, v.gr., vender un arado por un buey; donar un predio rústico en lugar de un inmueble situado en la ciudad de Roma, etc.

4. Error sobre las cualidades de la cosa (error in substantia). Recae sobre las características esenciales de la cosa, lo que cambia todo el sentido del negocio, v.gr., querer comprar aceite de oliva y, en cambio, adquirir aceite de maíz; un objeto de marfil por otro de nogal; etc.

5. Error sobre las cantidades tenidas en cuenta en el negocio (error in quantitate). Es aquel que recae sobre la cantidad o monto de las cosas, v.gr., locar mediante un canon de diez ases en lugar de cien ases; adquirir mil yugadas de tierra en lugar de cien, etc.⁽⁵⁴⁾.

4.2. El dolo

El célebre jurisconsulto romano clásico Ulpiano, en su estudio medular sobre el tema efectuado en el Digesto, da la razón al jurista Labeón respecto de la definición de dolo, cuando este último señala que dolo malo es "toda astucia, falacia, maquinación, empleada para sorprender, engañar o defraudar a otro"⁽⁵⁵⁾.

Dicho en otras palabras, dolo (dolus) es engañar a la otra parte causándole un perjuicio, es decir, la intencionalidad puesta de manifiesto en el propósito deliberado de engañar a la víctima, la cual, de otro modo, no hubiera consentido el acto jurídico.

Los juristas romanos diferencian en principio y desde antiguo dos clases de dolo: el malo y el bueno. El "dolo malo" (dolus malus) es aquel definido por Labeón y reafirmado por Ulpiano, o sea, cuando media la verdadera intención de engañar para perjudicar. En cambio, el "dolo bueno" (dolus bonus) es el engaño no nocivo, o sea, la astucia empleada sin intención de causar un ilícito ni perjuicio a la otra parte, sino esgrimido como una defensa lícita para enfrentar al enemigo, pícaro o ladrón.

También los juristas romanos reparan en que el dolo puede ser causado mediante una "acción o actividad positiva" destinada a engañar a la otra parte, a la que llaman "dolo verdadero" (dolus verus), y también mediante una "acción negativa, de omisión o reticencia", a la que denominan "dolo negativo" (dolus negativum)⁽⁵⁶⁾.

La jurisprudencia romana, especialmente el derecho honorario, brinda distintas soluciones jurídicas a aquellos que son víctimas de dolo; así, la "acción de dolo" (actio doli) y la "excepción de dolo" (exceptio doli).

La primera consiste en una acción creada por el pretor en beneficio de la víctima del dolo para obtener la reparación del daño padecido mediante la reposición de las cosas al estado anterior y, en caso contrario, ordena el pago de una indemnización por el perjuicio sufrido⁽⁵⁷⁾.

La segunda es también creada por el pretor como remedio procesal, con el fin de contrarrestar la acción interpuesta en perjuicio de la víctima por el autor del dolo, que persigue el cumplimiento del acto viciado⁽⁵⁸⁾.

Posteriormente, el derecho justinianeo continúa trabajando sobre las creaciones pretorianas, aunque mejorando su implementación, agilizando el aspecto procesal de la cuestión.

4.3. La violencia (*vis*)

De las fuentes se obtiene la definición de violencia como aquella fuerza material o psíquica ejercida sobre uno de los sujetos para que brinde su consentimiento en el negocio que de otro modo no hubiera otorgado. La violencia puede ser física o moral.

La violencia física (*vis absoluta* o *corpori illata*) implica la aplicación de medios y modos directos sobre la humanidad de la víctima para obligarla compulsivamente a llevar a cabo el negocio, v.gr., hacerle firmar por aplicación de la fuerza sobre su cuerpo o mano.

La violencia psíquica o moral (*vis compulsiva*, *metus*, *timor*) es también la aplicación de una fuerza compulsiva sobre la víctima, pero mediante una amenaza de sufrir un daño inmediato y grave sobre su persona o familiares directos⁽⁵⁹⁾.

Es también mérito del derecho honorario el tratamiento jurídico a favor de aquellos que son víctimas de la violencia, en cualquiera de sus formas, mediante la creación de la "acción por causa de violencia o miedo" (*actio quod metus causa*) y la "excepción de violencia o miedo" (*exceptio metus*).

La primera es creada por el pretor en favor de las víctimas de violencia en la concertación del acto jurídico, a fin de que puedan obtener una reparación pecuniaria consistente en el cuádruplo del daño padecido⁽⁶⁰⁾.

La segunda consiste en una defensa de carácter procesal para detener la acción instaurada por el autor de la violencia contra la víctima, con el fin de lograr la ejecución del negocio viciado⁽⁶¹⁾.

5. El objeto como elemento esencial⁽⁶²⁾

El objeto del negocio jurídico, según se desprende de las fuentes romanas, es su mismo contenido. No habrá de entenderse como aquello que resulta ser el objeto de la prestación, v.gr., la casa en la compraventa, sino, por el contrario, como la prestación en sí misma. Dicho más claramente, consiste en contemplar los intereses de las partes que intervienen en la celebración del negocio jurídico. Entonces, los juristas romanos, con buen tino, tienen en cuenta para cada caso en particular la regulación del objeto, por cuanto entienden, según se desprende del casuismo ya estudiado, que éste puede variar según la configuración de cada negocio. No obstante ello, de la labor de la jurisprudencia romana se desprenden ciertas pautas genéricas que luego, a manera de teoría general, es receptada por buena parte de las legislaciones de derecho privado del mundo occidental, incluso la nuestra.

Así, determina la jurisprudencia romana que el objeto del acto jurídico debe ser posible, tanto física como jurídicamente. La posibilidad física se refiere a que no debe ser contrario a las leyes de la naturaleza⁽⁶³⁾, y la jurídica, que no debe ser contrario a la ley⁽⁶⁴⁾. También el objeto debe ser determinado o al menos determinable. Es decir, perfectamente individualizado o susceptible de serlo⁽⁶⁵⁾.

Con el transcurso del tiempo, estas pautas básicas no sólo se consolidan, sino que se le añaden otras, v.gr., que se trate de cosas que estén en el comercio, que no tengan como fin un ilícito, etc., hasta configurar la idea moderna del tema.

6. La causa como elemento esencial⁽⁶⁶⁾

Respecto de la causa en el negocio jurídico, es menester dejar en claro que los juristas romanos la tienen perfectamente en cuenta como elemento esencial de aquél, pero sin una configuración general o teórica, sino determinada para cada caso en particular. Así, conocen y aplican "la causa fin" como el motivo tenido en cuenta por las partes, v.gr., en el comodato, conseguir la cosa prestada⁽⁶⁷⁾; y "la causa fuente" como el acto que le da origen, v.gr., la traditio⁽⁶⁸⁾.

VI. LOS ELEMENTOS ACCIDENTALES DEL NEGOCIO JURÍDICO⁽⁶⁹⁾

Se entiende por elementos accidentales del negocio jurídico (*accidentalia negotii*) a las modalidades insertas por las partes, no contrarias a la ley, y que no hacen a la existencia de éste, pero que, una vez convenidas, alteran sus efectos.

Resulta primordial dejar en claro que los elementos "esenciales" deben encontrarse siempre presentes en el acto para que éste exista, mientras que los "accidentales" pueden o no estar, e igualmente ello no afecta la existencia del acto.

Los elementos accidentales del negocio jurídico, que incluso las fuentes denominan en diversos pasajes como "modalidades", son: la condición, el plazo y el modo.

1. La condición (*condicio*)

Es el acontecimiento futuro e incierto del cual las partes hacen depender el nacimiento o la finalización de los efectos del acto jurídico. En primer lugar, debe considerarse que el acontecimiento se debe producir en el futuro, es decir, en el porvenir. Éste no puede haber acontecido con anterioridad y que las partes lo desconozcan como tal al momento de celebrar el acto, sino que efectivamente debe ser futuro. En segundo lugar, el acontecimiento debe ser incierto, es decir que puede o no acontecer. Precisamente la incertidumbre es la característica propia de la condición, por cuanto si el acontecimiento es cierto no se trata de condición, sino de plazo⁽⁷⁰⁾.

Existen dos tipos de condición: la suspensiva y la resolutoria. La condición suspensiva es aquella que supedita la entrada en vigor de los efectos del negocio jurídico a la producción del acontecimiento futuro e incierto, v.gr., el día que te recibas de abogado (*advocatus*) te daré mi biblioteca de libros jurídicos⁽⁷¹⁾. En cambio, la condición resolutoria es aquella que pone fin a los efectos del negocio jurídico, resolviéndolos cuando se produce el acontecimiento futuro e incierto. A diferencia de la condición suspensiva, en ésta el acto comienza a generar efectos una vez celebrado, los cuales fenecen una vez cumplido el acontecimiento futuro e incierto, v.gr., te doy mi biblioteca de libros jurídicos hasta tanto te recibas de abogado⁽⁷²⁾.

Debe destacarse que, a la luz de las fuentes, los juristas clásicos trabajan en principio con la condición suspensiva, y luego, tras evolucionar, comienza a considerarse y aplicarse la condición resolutoria.

Es interesante hacer hincapié en el estudio que efectúan los juristas romanos respecto de los distintos efectos que se generan, tanto en la condición suspensiva como en la resolutoria, según los siguientes supuestos: que la condición aún no se haya cumplido, que se haya cumplido y que nunca se pueda cumplir.

Primero analizaré estos efectos en la condición suspensiva.

— El supuesto de condición pendiente (*pendente condicione*) no genera efectos, por cuanto la condición no se ha cumplido. Más tarde, en el período justiniano, se le reconoce al interesado "la legitimación de una expectativa de derecho" para el caso en que se le intente burlar ese derecho, brindándole protección y facultándolo a exigir indemnización por los daños y perjuicios padecidos, en caso de ser necesario.

— El supuesto de condición cumplida (*existente condicione*) es el acaecimiento del hecho futuro e incierto, el cumplimiento simple y natural de la condición y, por ende, nace ipso facto la exigibilidad de todos los derechos que se encuentran supeditados a ella.

— El supuesto de la condición frustrada (defecta condicione) se da cuando las partes involucradas tienen la certeza de que la condición jamás se va a cumplir. En este caso se considera como que el negocio nunca se concertó, sin generar ningún efecto para las partes, incluso se extingue la expectativa o protección que se brinda en salvaguardia de los posibles derechos del favorecido⁽⁷³⁾.

También existen otros tipos de condiciones conocidas por el derecho romano, a saber: positivas y negativas; potestativas, casuales y mixtas; posibles e imposibles.

— Las condiciones positivas son aquellas que contemplan el efectivo cumplimiento de un hecho ("que te recibas de advocatus"), mientras que las negativas son las que se encuentran subordinadas al no cumplimiento de un hecho ("que no te recibas deadvocatus").

— Las condiciones potestativas son las que dependen de una actitud de la persona a quien está dirigida, es decir, de un hecho a llevar a cabo por ésta; así, "si subes al capitolio", "si descendes del navío". No son consideradas válidas aquellas que únicamente dejan supeditado el acontecimiento a la simple voluntad de una de las partes; v.gr., "te regalaré mi caballo si tú quieres".

Las casuales, por el contrario, son aquellas que dependen de un acontecimiento ajeno a la voluntad de las partes. El hecho contemplado en la condición es extraño a una actitud propia del interesado; v.gr., "el arribo de un navío de Egipto".

— Las mixtas son las condiciones que se encuentran subordinadas a un hecho que participa de las características de las dos anteriores, es decir, que en parte es producto de una actitud propia de la parte interesada, y en otro aspecto resulta ajeno a la ella; por ejemplo, "me darás mil áureos si te recibes de advocatus en Roma".

— Las condiciones posibles son las que pueden cumplirse o llevarse a cabo, v.gr., "recibirse de advocatus", "casarse con Ticia". En cambio, las imposibles son aquellas que directamente nunca pueden concretarse, son en verdad de cumplimiento imposible; así, "tocar el cielo", "comprar el foro", etc.⁽⁷⁴⁾.

FRANJA
MORADA

2. El plazo (dies)

Es el acontecimiento futuro y cierto del cual las partes hacen depender el nacimiento o la finalización de los efectos del negocio jurídico. Es un rasgo distintivo del plazo la certidumbre respecto del acontecimiento futuro, el cual inexorablemente va a suceder.

Precisamente, la diferencia con la condición radica en que mientras aquélla puede o no ocurrir, el plazo siempre va a acontecer.

El plazo puede ser suspensivo (dies a quo) o resolutorio (dies ad quem). El primero supedita el nacimiento de los efectos a la exigibilidad al momento en que se produzca su cumplimiento; v.gr., "te prestaré mi biblioteca de libros jurídicos a la muerte del tío Rufo". El segundo comienza a generar efectos una vez celebrado el mismo, pero hasta el momento en que se cumpla el plazo; v.gr., "te prestaré mi biblioteca de libros jurídicos hasta el día que muera el tío Rufo".

Los efectos del plazo deberán ser analizados únicamente durante las etapas de pendencia y de cumplimiento, por cuanto la etapa de frustración no existe, dado que el acontecimiento futuro es siempre cierto. El plazo suspensivo durante el período de pendencia se encuentra perfectamente válido y a la espera del cumplimiento del término para comenzar a generar los efectos pactados. El plazo resolutorio durante el período de pendencia surte plenamente los efectos entre las partes hasta que se produce su vencimiento, resolviéndose en dicho momento⁽⁷⁵⁾.

3. El modo (modus)

Es la carga impuesta a título gratuito a la persona beneficiada por una liberalidad para que cumpla con determinado comportamiento; v.gr., "lego un millón de ases a Tulio con el fin de que utilizare una parte de dicha suma en mantener a mi fiel esclavo Servio hasta que éste muera".

Durante el período del derecho quiritarario, el cumplimiento del modo queda librado sólo a la voluntad de la persona que debe llevarlo a cabo. Luego, durante el derecho clásico, se asegura su cumplimiento con una caución (cautio). Más tarde, en el derecho justinianeo, se le otorga al beneficiario del modo diversas acciones para asegurar el cumplimiento (actio praescriptis verbis, actio rei vindicatio utilis, etc.⁽⁷⁶⁾).

VII. LOS DENOMINADOS ELEMENTOS NATURALES DEL NEGOCIO JURÍDICO (NATURALIA NEGOTII)⁽⁷⁷⁾

Se denomina, por lo general, elementos naturales del negocio jurídico a aquellos que no son esenciales para la constitución del acto, pero que hacen a su propia naturaleza. Pueden ser considerados aun cuando las partes no los prevean y dejados expresamente de lado por ellas.

Es mi opinión, como ya lo adelantara, considerar únicamente como elementos del negocio jurídico los denominados esenciales y accidentales. Es más, puedo afirmar que de la jurisprudencia romana se obtiene que los juristas clásicos enseñan fundamentalmente como elementos del negocio jurídico los llamados esenciales, y al hacer referencia a los accidentales los denominan, muchas veces, modalidades del negocio jurídico. Posteriormente, con la escuela pandectística, se le brinda la terminología moderna de elementos esenciales y accidentales, considerándose también como elementos del negocio jurídico a los naturales.

Estos últimos sólo se encuentran en la compraventa, como defensa o garantía del comprador, y son los denominados "vicios redhibitorios" y "garantía de evicción". Los primeros constituyen "los vicios ocultos" que presenta la cosa; y la segunda, el derecho de reclamar la cosa a un tercero que lo priva de ella, siempre que el vendedor no la entregue⁽⁷⁸⁾.

Por tal motivo, a mi criterio, no debe considerarse a los denominados elementos naturales del negocio jurídico como tales, por cuanto sólo se encuentran presentes en la compraventa, y por ello no se deben extender para el acto jurídico en general⁽⁷⁹⁾.

VIII. INEFICACIA DEL NEGOCIO JURÍDICO⁽⁸⁰⁾

El derecho romano, poco afecto a la elaboración precisamente de "teorías generales", como se ha visto reiteradamente, tampoco lo lleva a cabo respecto de "la ineficacia del negocio jurídico". Por el contrario, se basa en analizar cada caso concreto sometido al análisis de los juristas. Por eso se determina que las principales causas de ineficacia del negocio jurídico estriban en los vicios o falencias contenidas en los elementos del negocio, v.gr., consentimiento, objeto del negocio, etc.

Posteriormente, la doctrina moderna, partiendo del estudio de la proficua labor de los juristas romanos, elabora la teoría sobre la ineficacia del negocio jurídico, determinando cuándo un acto es nulo o anulable, y en su caso, si la nulidad es absoluta o relativa, estableciendo además las consecuencias que emanan del acto viciado.

Capítulo XVIII - El Patrimonio

CAPÍTULO XVIII - EL PATRIMONIO

Los romanos definen el patrimonio (*patrimonum*) como aquellos "bienes que el hijo tiene heredados de su padre o abuelo", encontrándose allí el origen etimológico del término jurídico que hoy en día conocemos.

En la actualidad se considera el patrimonio como "un atributo de la personalidad", y está compuesto por la totalidad de los bienes y derechos susceptibles de apreciación pecuniaria, como así también por los gravámenes que éstos presentan. Éste constituye un ente distinto de los bienes que lo integran, y por ello todos los individuos resultan titulares de un patrimonio, aunque sólo esté integrado por deudas.

Sin embargo, los romanos tienen una concepción distinta. Para éstos el patrimonio, en un principio, sólo está integrado por los bienes corpóreos. Posteriormente, comienzan a considerar que el mismo constituye un ente jurídico tutelado por la ley, conformado por todos aquellos bienes, créditos, derechos y acciones que tiene un sujeto luego de deducir sus deudas. Esta concepción es receptada por Justiniano, quien lo define como "todo aquello que quedará después de deducidas las deudas"⁽¹⁾.

Como los romanos consideran que el patrimonio es un ente jurídico, éste no sólo puede transmitirse *mortis causa*, sino también por actos *inter vivos*, como, por ejemplo, la "adrogación", mediante la cual el patrimonio de un *sui iuris* se transmite al "adrogante", y también en los supuestos de legitimación y el matrimonio *cum manu*, cuando la mujer es *sui iuris*. Incluso conciben la posibilidad de que exista un patrimonio con capacidad para adquirir derechos y obligaciones sin titular, como ocurre con la "herencia yacente" (*hereditas iacens*), o que exista una persona sin patrimonio, ya sea porque no tiene ningún bien, o porque sus deudas superan el valor de sus bienes⁽²⁾. En este último sentido, el hijo (*filius*) carece de patrimonio propio durante un período extenso de tiempo.

Ello permite colegir que los romanos no consideran al patrimonio como un atributo de la personalidad, sino que constituye un ente jurídico únicamente integrado por valores positivos, es decir que se excluyen de él las deudas o cargas que un individuo contrae.

I. COMPOSICIÓN

Como ya expresara precedentemente, el patrimonio para los romanos está compuesto por todos los bienes, créditos, derechos y acciones que tiene una persona, incluyendo tanto los derechos que hoy llamamos personales como los reales. Se encuentran excluidos de este concepto todos aquellos derechos que no son susceptibles de una valuación económica, v.gr., el derecho a la existencia, al honor y los derechos políticos relativos al ejercicio de la ciudadanía, como, por ejemplo, el *ius suffragii* y el *ius honorum*. Tampoco conforman el patrimonio los derechos que le otorgan a una persona la potestad sobre otra, como los derivados del matrimonio, patria potestad y los correspondientes a los tutores o curadores respecto de sus pupilos.

Los derechos personales son aquellos por medio de los cuales una persona le puede exigir a otra el cumplimiento de un hecho o una abstención. En cambio, los reales se ejercen directamente sobre las cosas, creando una relación directa entre el titular del derecho y la cosa sobre la cual recae.

Las fuentes romanas no establecen una clara distinción entre los derechos reales y personales, pero, en cambio, distinguen entre acciones *in rem*, cuyo tipo es la *vindicatio*, y acciones *in personam*, como las *condictiones*⁽³⁾. En estas últimas el demandado siempre debe ser el deudor, mientras que las primeras son *erga omnes*, ya que pueden intentarse contra cualquiera que desconozca el derecho que se tiene sobre la cosa o intente menoscabar su plenitud o libertad⁽⁴⁾. Los

derechos personales, eventualmente y en forma mediata, pueden acarrear o producir efectos sobre las cosas.

Los derechos reales se dividen en "derechos sobre la cosa propia" (iura in re) y "sobre la cosa ajena" (iura in re aliena). Entre los primeros se encuentra el derecho de propiedad o dominio, y entre los segundos, instituciones del derecho civil como la servidumbre o del derecho pretoriano, como el ius in agro vectigali, la enfiteusis, la superficie y la hipoteca.

La posesión no puede incluirse en ninguna de estas categorías, ya que implica un poder que puede ejercerse tanto sobre cosa propia como ajena, en forma directa e inmediata.

II. EL CONCEPTO DE COSA. CLASIFICACIÓN

Brindar el concepto de cosa, según la jurisprudencia romana, no es tarea sencilla. Se la conoce como res, palabra latina, que, al igual que el término "cosa" en castellano, está sujeta a acepción e interpretación tan variada como compleja, dado que todo aquello que en definitiva no puede ser determinado con precisión es denominado genéricamente res; v.gr., res publica ("cosa pública"), etc.

Efectuada esta breve aclaración a modo de introducción, me encuentro en condiciones de señalar que en Roma son cosas todos los objetos corporales e incorporeales sometidos al poder del hombre y susceptibles de apreciación económica, es decir, en otras palabras, todo aquello externo que le proporciona una utilidad, un servicio, una ventaja⁽⁵⁾.

Las fuentes nos proporcionan la preocupación evidente de los juristas en clasificar las cosas, conociendo su importancia para el derecho. Por razones de claridad, al referirme al tema, desde hace tiempo, lo he dividido en dos aspectos, teniendo en cuenta para ello su receptividad en nuestro derecho, facilitando su mejor comprensión y utilidad. De tal modo, me refiero a la clasificación romana antigua y moderna, diferenciándolas entre sí para lograr de este modo que se conozca la propia evolución de la jurisprudencia romana, que en definitiva se depura y mejora a sí misma, iniciándose de un modo y avanzando, hasta ser aquella tenida en cuenta por la legislación moderna.

III. LA ANTIGUA CLASIFICACIÓN ROMANA DE COSAS

Es la que difunde, en principio, mayormente Gayo y luego es superada por aquella que considero "moderna". Con base en ella se encuentran, por un lado, las "cosas del derecho divino" (res divini iuris) y, por otro, las "cosas del derecho humano" (res humani iuris).

1. Cosas del derecho divino (res divini iuris)

Están consagradas a los dioses y sometidas a los pontífices, encontrándose como consecuencia de ello fuera del comercio y ajenas a los actos de la vida jurídica. No pertenecen a los particulares por motivos religiosos y por esto también reciben la denominación de res nullius, ya que ningún ser humano puede apropiárselas⁽⁶⁾.

Esta clasificación, a su vez, se subdivide del siguiente modo:

1.a. Cosas sagradas (res sacrae). Son los objetos destinados al culto; v.gr., los utensilios, los vasos y los templos. Para adquirir este carácter, las cosas deben ser objeto de una declaración legal que así lo establezca, realizándose al efecto la ceremonia de la "consagración" (consagratio), en la

que intervienen el magistrado y los pontífices. Por el contrario, para desafectar una "cosa sagrada" se lleva a cabo una ceremonia inversa, denominada profanatio⁽⁷⁾. Si una "cosa sagrada" cae en poder del enemigo, cesa su condición, y si con posterioridad es rescatada por los romanos, la recupera. Las res sacrae son consideradas por los romanos como propiedad de la divinidad. Con el advenimiento del cristianismo, sólo revisten esta condición los elementos utilizados para la celebración de la ceremonia cristiana, resultando necesaria para su consagración únicamente la participación del obispo⁽⁸⁾.

1.b. Cosas religiosas (res religiosae). Se considera así al suelo que sirve para recoger los restos mortales de una persona, aunque se trate de un esclavo; v.gr. el sepulcro. En un principio sólo se encuentran dentro de este tipo los lugares en los cuales se encuentran sepultados los antepasados, es decir, los dioses "manes", pero con Justiniano se amplía a todos aquellos lugares donde se inhume un cadáver. Sólo es religioso el lugar que ocupa el despojo y no reviste tal condición el sepulcro vacío ("cenotafio")⁽⁹⁾. Solamente pueden tornarse religiosos por inhumación los terrenos donde han sido enterrados sus propietarios. En caso de que se entierre un cadáver en un terreno ajeno sin el consentimiento de su dueño, el lugar no se vuelve religioso, pero ello no le confiere autorización al propietario para exhumar el cadáver. Pero si el dueño la otorga con posterioridad al entierro, el lugar se vuelve religioso⁽¹⁰⁾. Las inhumaciones en el interior de las ciudades están prohibidas por razones de salud pública y también a causa de supersticiones. Los cementerios, en el sentido moderno que conocemos, surgen con posterioridad.

1.c. Cosas Santas (res sanctae). Las constituyen aquellas cosas que, sin ser sagradas, están protegidas por una sanción penal para quien las viole; v.gr., los muros, las puertas de las ciudades. Las cosas santas revisten esta condición luego de una ceremonia especial llevada a cabo por el colegio de los "augures", mediante la cual se las coloca bajo la protección de los dioses. Es de recordar en este aspecto la leyenda de la fundación de Roma, cuando Rómulo ejecuta a su hermano Remo por violentar los límites de la nueva civitas.

2. Cosas del derecho humano (res humani iuris)

Esta categoría está conformada por aquellos objetos excluidos del comercio por una causa de interés general. Se encuentran al servicio de los particulares. Son las siguientes:

2.a. Cosas comunes (res communis). Consisten en aquellas cosas que por su propia naturaleza se encuentran sometidas al libre uso del género humano. Su utilización es general, aunque no son susceptibles de apropiación por los particulares, v.gr., el aire, el agua corriente, el mar y sus costas, el sol, etc.⁽¹¹⁾.

2.b. Cosas públicas (res publicae). Son aquellas que le pertenecen al pueblo romano considerado como comunidad políticamente organizada, sobre las cuales ejerce un verdadero derecho de propiedad que le permite excluir su uso a otros pueblos. Las cosas públicas son consagradas a través de una ceremonia especial llamada publicatio y se encuentran dentro de este grupo, entre otros, los caminos, los lechos y orillas del río, etc.⁽¹²⁾. Todos los integrantes del pueblo romano pueden utilizarlas, siempre y cuando no obstaculicen o impidan su uso por parte de los demás. Asimismo, dentro de esta clasificación, se incluyen cosas que son susceptibles de tráfico comercial y que le pertenecen al pueblo romano; por ejemplo, el dinero que integra el tesoro público, el producto de los impuestos, los esclavos y los terrenos públicos, etc.⁽¹³⁾.

2.c. Cosas universales (res universitatis). Son objetos que integran el patrimonio de los sujetos de existencia ideal, como las ciudades y las corporaciones, y que se encuentran afectados al uso de sus miembros; v.gr., los teatros, los lugares de estudio, los lugares donde se llevan a cabo las carreras, los baños públicos de las ciudades, etc.

2.d. Cosas privadas (res privatae). Es la categoría compuesta por las cosas susceptibles de apropiación por parte de los hombres. Éstas se encuentran dentro del comercio y pueden integrar el patrimonio de los particulares. Se subdividen, a su vez, del siguiente modo:

2.d.1. Cosas Mancipi (res Mancipi). Según Gayo, son aquellas cosas que sólo pueden transmitirse mediante los sistemas antiguos solemnes de la Mancipatio y la in iure cessio; v.gr., los fundos y las casas situadas en Italia o en aquellos lugares que gozan del ius Italicum, las servidumbres sobre dichos fundos, los esclavos y las bestias de carga y tiro (bueyes, caballos,

mulas, asnos, etc.). Estas cosas se inscriben en los registros del censo y sólo es su propietario quien figura en ellos con tal calidad; por eso se exige la transcripción en el censo.

2.d.2. Cosas no mancipi (Res nec mancipi). Se transmiten por la simple tradición de la cosa sin que resulte necesaria formalidad alguna. En este grupo se encuentran el resto de las cosas corporales; v.gr., los fundos provinciales, los animales salvajes y domésticos, las joyas y el dinero.

IV. LA MODERNA CLASIFICACIÓN ROMANA DE COSAS

1. Consumibles

Son las que perecen con el primer uso que de ellas se haga. Su función principal es satisfacer las necesidades básicas del hombre; v.gr. los comestibles, el dinero, etc.

2. No consumibles

Son aquellas que no desaparecen con el primer uso, pero pueden deteriorarse con el paso del tiempo e incluso pueden llegar a consumirse por su uso prolongado; v.gr., el vestido, un escritorio, una cama, etc.

3. Fungibles

Se caracterizan por formar parte de un género tan homogéneo que todo individuo de una especie es similar a cualquier otro de la misma especie, de tal modo que pueden reemplazarse unos a otros teniendo en cuenta peso, número, medida y calidad⁽¹⁴⁾; v.gr., las legumbres, el trigo. El principal elemento que se incluye en esta categoría es la moneda (pecunia).

4. No fungibles

Las que no pueden sustituirse unas por otras, por cuanto tienen individualidad propia que hace que no sean iguales entre sí, aun perteneciendo a la misma especie; v.gr., un caballo, una casa, etc.

5. Divisibles

Las que pueden ser reducidas en varias partes, conservando cada una de ellas la esencia y función propia del todo; v.gr., las legumbres, la tierra, etc.

6. Indivisibles

Son aquellas que no se pueden dividir porque pierden la esencia y función del todo; v.gr., un animal.

7. Principales

Las que por su propia existencia y naturaleza están determinadas por sí solas, sirviendo inmediatamente por ellas mismas a las necesidades del hombre, sin depender de otra cosa; v.gr., un fundo.

8. Accesorias

Las que por su existencia y naturaleza dependen de otra cosa principal sin la cual no existen; por ejemplo, un árbol⁽¹⁵⁾. Lo accesorio siempre debe seguir la suerte de la cosa principal. El concepto de accesión comprende no sólo la incorporación de una cosa a otra, sino que también se aplica a los derechos.

Según su naturaleza, se dividen en accesorias por incorporación y accesorias por su destino. Las primeras son aquellas cosas que están unidas a otras de modo que forman con ellas un todo, como, por ejemplo, los materiales con los que se ha construido una casa. Las segundas son los productos naturales u orgánicos de una cosa, que periódicamente se extraen conforme a su destino económico, adquiriendo individualidad propia por su separación y constituyendo su renta; v.gr., los frutos. Se distinguen los frutos naturales (v.gr., lana, leche, etc.) de los civiles (por ejemplo, alquileres de una casa o intereses del capital); también se incluyen dentro de esta categoría los frutos industriales, que son aquellos que se obtienen del trabajo del hombre⁽¹⁶⁾.

Las cosas accesorias fortuitas son aquellas que se producen por causas accidentales, como, por ejemplo, el aluvión, la avulsión, etc., y provocan un aumento del valor de aquella cosa a la cual acceden.

9. En el comercio

Se encuentran dentro del tráfico jurídico, por cuanto pueden ser objeto de un negocio; v.gr., una casa, un arado, etc.

10. Fuera del comercio

Son aquellas que están fuera del tráfico jurídico. Se encuentran dentro de esta categoría las llamadas res delictae, es decir, aquellas cosas que han sido abandonadas por su dueño, y las denominadas res nullius, aquellas que no pertenecen a nadie en particular.

11. Simples

Las que forman un todo, una unidad, sin que se destaquen sus componentes; v.gr., las piedras, un animal.

12. Compuestas

Las que se dan por la unión de cosas simples; v.gr., una nave.

13. Universales

No tienen un lazo material entre sí, pero se las considera una unidad por su función económica social, circunstancia que las convierte en un objeto unitario de relaciones jurídicas que permanece idéntico e invariable aunque las cosas que lo componen aumenten, disminuyan o se renueven; v.gr., un rebaño, una biblioteca, etc.

14. Muebles

Son las que, por su propia esencia y su uso económico, pueden trasladarse de un lugar a otro. Constituyen una categoría especial dentro de ella los semovientes (ses moventes), que pueden trasladarse por sí mismos, como los animales y los esclavos⁽¹⁷⁾.

15. Inmuebles

Lo son el suelo y todo aquello que se encuentre adherido a él, por lo que no pueden desplazarse de un lugar a otro, como, por ejemplo, una casa o un fundo. Pueden clasificarse en inmuebles por su naturaleza (como el suelo y todo lo que se encuentra debajo); inmuebles por incorporación (es decir, aquellas cosas muebles unidas al suelo, ya sea de manera orgánica, como un árbol, o de manera artificial, como los edificios); e inmuebles por su destino (considerándose así a los objetos muebles colocados por el propietario del fundo para su explotación, como por ejemplo los implementos agrícolas, los esclavos, etc.). Éstos pierden su calidad de inmuebles cuando son separados del terreno al cual están anexados⁽¹⁸⁾.

**FRANJA
MORADA**

CAPÍTULO XIX - LA POSESIÓN

Puede ser definida como el poder de hecho que se ejerce sobre determinada cosa corporal, propia o ajena, independientemente de la legitimidad que se tenga para hacerlo, con la intención de retenerla y disponer de ella como lo hace un propietario. A través de ella se materializa el derecho de propiedad y todos los restantes derechos que derivan de éste. En síntesis, la posesión es un señorío de hecho sobre una cosa, mientras que la propiedad constituye un señorío de derecho.

Consta de dos elementos: el corpus, poder físico que se ejerce sobre la cosa, y el animus, intención del individuo de tener la cosa y disponer de ella como si fuera el titular del dominio.

Es necesaria la presencia simultánea de ambos elementos para que la posesión tenga consecuencias jurídicas y su correlativa protección⁽¹⁾.

I. LAS DISTINTAS CLASES DE POSESIÓN

1. Posesión justa (iusta) e injusta (iniusta)

La primera es aquella que se obtiene sin causarle ningún daño al anterior poseedor, es decir que se adquiere por un medio legal y sin vicio de origen. Por ello, también se la llama posesión no viciosa.

La posesión injusta implica que se le ha causado una lesión al antiguo poseedor y se distingue, según el vicio mediante el cual se la adquiere, en violenta (vi), clandestina (clam) y precaria (precario). La posesión viciosa se origina cuando se ejerce sobre el antiguo poseedor fuerza física o intimidación a fin de expulsarlo, también cuando al poseedor se le imposibilita ejercer alguna resistencia a fin de salvaguardar su derecho o cuando el nuevo poseedor se apodera de la propiedad en su ausencia y a su regreso no se le permite ingresar⁽²⁾. La posesión es clandestina cuando se obtiene ocultamente y el antiguo poseedor ignora que esto ocurre, de manera que no puede oponerse⁽³⁾, y precaria cuando quien sólo tiene el uso de la cosa se niega a devolverla, pese a que se le ha reclamado debidamente⁽⁴⁾. A pesar de las diferencias existentes entre la posesión justa y la injusta, ambas se encuentran protegidas por el derecho positivo⁽⁵⁾.

2. Posesión de buena y mala fe

En el primer caso, el poseedor cree que está legitimado y que tiene derecho para hacerlo, mientras que en el segundo el poseedor no tiene dicha convicción y conoce que su accionar no encuentra respaldo en ningún derecho⁽⁶⁾. La buena y la mala fe pueden darse tanto en la posesión justa como en la viciosa.